



Introduction

A - Vocabulaire

Droit des obligations = droit des contrats.

Au S3 on a fait du droit commun des contrats. Le droit de la responsabilité civile est la poursuite de ce cours.

C'est avec l'article 1105 du Code civil qu'on délimite les contrats et les contrats spéciaux.

Ils y a des contrats qui n'obéissent qu'aux règles générales, et d'autre qui n'obéissent qu'aux règles spéciales.

On va s'intéresser a la distinction : règle commune / règle générale / règle spéciale

Il n'existe pas des « contrats spéciaux » car chaque contrat est spécial. On a créé un droit commun des contrats.

Le code civil donne une série de catégorie avec des contrats nommés, en les nommant le législateur leur donne des règles spéciales. Ces règles sont spécialement applicables à ces types de contrat uniquement.

B - Qualification

L'opération de qualification est essentielle car elle pose le cadre juridique applicable.

Pour savoir quel type de contrat on detiens, on va chercher les définitions des différents types de contrats, puis voir si les éléments sont présents dans le contrat.

Bail	.	Vente	.
Mandat	.		.
	.		.

Commune = classification
Règles juridiques de la vente

On va reconnaître des contrats ppur les qualifier et leur appliquer les bonnes règles. Parfois il existe des contrats complexe, qui résultent d'un assemblage entre différentes qualifications.

Pour qualifier les contrats complexes : on regarde l'obligation la plus importante

Par exemple : le contrat de déménagement : englobe le transport, la manutention, parfois du service, la sécurité, etc. ->

C'est un contrat d'entreprise et pas de transport.

On peut aussi appliquer une **qualification mixte** : le contrat se décompose dans le temps et on va appliquer des qualif successives. Dans un premie temps c'est un contrat de service, ensuite de transport et enfin de vente.

On peut aussi faire une **qualification distributive** distribuer, il y a une partie vente, une partie location et une partie mandat.

Enfin il y a la **qualification unique**, on choisi une qualif et on exclue toute les autres.

C - Domaine et sources

Le domaine du droit spécial des contrats est difficile a délimiter. Lors de la codification du Code en 1804, une grande partie de la population ne savait ni lire ni écrire. Ils ne pouvaient donc pas suivre les règles imposées par le Code. On a alors inventé le « supplétif » pour suppléer le silence des parties. Le CC va venir suppléer le silence de la partie de la population qui ne sais pas lire.

La supplétivité laisse donc de la liberté, car elle n'intervient que si les parties n'ont rien prévu dans leur contrat par rapport à certaines questions (frais de livraison, date de livraison, etc).

=> Règles spécifiques pour des contrats spécifiques mais qui sont des règles supplétives

Ce ne sont pas des contrats spéciaux car ce sont les contrats les plus usuels.

Le problème c'est que parmi tous ces contrats il faut désormais faire des distinctions. Par exemple le contrat de travail est évoqué dans 2 articles dans le CC mais code entier en traité aussi.

Il faut faire une sélection entre ces contrats les plus usuels et les contrats les plus spéciaux (comme le contrat de mariage ou le contrat de travail).

Il y a aussi des contrats qui se sont segmentés, etc. Selon les époques il y a des contrats très peu utilisés, et puis en quelques années ils deviennent très utilisés.

En 1804, il y avait les grands contrats de l'époque : la vente, le bail et les contrats d'entreprise. Les contrats moins utilisés étaient le dépôt, le prêt ou le mandat. C'est que ces contrats étaient moins importants car intuitu personae et « gratuit », ils n'engageaient rien.

Mais ce classement a été bouleversé, aujourd'hui il y a beaucoup de mandataires professionnels par exemple.

Parfois la règle spéciale écarte une partie du droit commun. Mais au départ elles viennent s'ajouter. Petit à petit, aujourd'hui, les sources du droit spécial des contrats ne sont plus que dans le CC. Il y en a ailleurs, dans d'autres codes. Dans des lois spéciales, par exemples.

Le droit spécial des contrats est aussi un droit qui concerne une institution juridique qui est laissée à une grande liberté des parties.

Projet de réforme : 2017, association Henri Capitan

On est passé aujourd'hui du supplétif à l'impératif

Il y a aujourd'hui une hyperspécialisation des contrats

- objective : (règles très spécifiques à des situations, cas particuliers).

- subjective : entre le professionnel et le consommateur, professionnel et non professionnel etc

Il y a également la complexification avec des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories etc.

I - Les contrats relatifs aux biens

Titre 1 : Les contrats translatifs de propriété

L'exemple type du contrat translatif est la vente. C'est le premier qui est traité dans le Code Civil.

Chapitre 1 : Le contrat de vente

Traité dans le CC aux chapitres **1582 a 1701**. C'est le modèle de tous les autres contrats.

Section 1 : Définition de la qualification

La def est donnée à l'art **1582 al 1 du CC**. C'est une convention dans laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. = cette définition ne tiens pas la route. Elle est approximative car elle ne donne pas les éléments de reconnaissance du contrat de vente. Or la définition doit servir à reconnaître. Heureusement il y a **l'article 1583 CC** qui nous permet d'y réfléchir. « ... » on a les éléments d'une définition. Ce qui compte dans la vente c'est que les parties aient convenu d'un **transfert de propriété**, qui porte sur une **chose**, et qu'il se fasse en **contrepartie d'un prix**. Une vente n'en a pas une s'il n'y a pas ces 3 éléments.

Il y a des éléments qui permettent de qualifier le contrat parmi tous les contrats de vente (synallagmatique, unilatéral, onéreux, etc.).

Pour la vente on parle de vendeur, venderesse, et d'acheteur ou d'acheteuse.

Il existe des biens corporels que l'on peut toucher, et des biens incorporels, que l'on ne peut pas toucher. Lorsqu'on parle de vente de bien corporel on parle de **vente**, pour les incorporels on parle de **cession** (cession de droits d'auteur, cession de parts, cession de société etc.).

On va essayer de distinguer le contrat de vente des autres contrats. Il faut un bien, il est au cœur du contrat de vente. Ça fait la diff avec les contrats où il n'y a pas de chose au milieu du contrat (contrat de travail, contrat d'entreprise, etc.).

=> Quand on va dans une agence de voyage on n'achète pas un voyage, on paye un service, c'est donc une prestation de service, pas une vente de service.

Il y a également le transfert de propriété. Dans certains contrats il n'y a pas de transfert de propriété, comme dans le bail, le locataire n'achète pas le bien, il le loue, il n'est pas à lui.

Il y a aussi une difficulté concernant le dépôt / vente : technique de distribution commerciale. On ne sait pas trop si c'est un dépôt ou une vente. Ce n'est pas un dépôt car pas de restitution du bien. Ça peut être un mandat, ou encore une vente conditionnelle, en ce sens qu'il y a une vente mais qui est passée sous conditions (suspensive ou résolutoire).

Enfin, le prix. On parle de somme d'argent. Pour qu'il y ait une vente il faut un transfert d'une somme d'argent. On ne peut pas échanger contre quelque chose d'autre parce que sinon c'est un autre contrat. Il y a pas exemple la donation, il n'y a pas carrément pas de contrepartie (parfois peut y en avoir, c'est la donation avec charge). Il y a aussi l'échange : on échange un téléphone contre un Ipad. Il n'y a pas de prix, ce n'est donc pas une vente.

La vente fait l'objet d'un mouvement d'hyperspécialisation, encore plus que dans les autres contrats. On a bcp de catégories très spéciales pour des ventes très spéciales (vente d'immeuble, vente d'électroménager, vente en ligne etc.).

Section 2 : La formation du contrat

La vente est soumise aux règles de droit commun, en tout cas pour l'essentiel. Mais il existe quelques règles spéciales. Ces règles spéciales doivent être mises en avant pour comprendre comment se forme la plus part des contrats de vente.

CM3 : 26/01

Paragraphe 1 : La préparation du contrat

La vente est la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Mais en réalité ce n'est pas toujours ça. Il y a des contrats de vente qui se forment avec un long processus de préparation, de négociation etc.

A - Vente a l'agréeage

- Vente a l'agréeage (contrat de gré a gré) **article 1587 Code Civil** : ces contrats sont prévues par le Code Civil. La première forme est la vente a la dégustation : vin, huile, etc. -> Il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûté et agréé. = c'est selon le goût de l'acheteur. Aussi, le vendeur ne peut pas discuter du bon goût de l'acheteur, car c'est une question personnelle, c'est a la discrétion de l'acheteur.

Ces vente à l'agréeage ne se retrouvent pas partout. Par exemple, on ne retrouve cette forme de vente dans les supermarché, ni chez un caviste. En général ce sont des professionnels, qui achètent le produit en grande quantité etc. Aussi, il n'y a pas que le vin et l'huile, il y a aussi le thé, le riz, etc. Il faut que cette vente soit prévu par les parties, ou dans un contexte particulier

-> Vente à l'essai : **Article 1588 Code Civil** : toujours présumée faite sous condition suspensive. Mais on ne nous dit pas ce qu'est une vente a l'essai, il donne seulement son régime. Mais on se rend compte que dans toutes les ventes a l'essai qu'on connaît, il ne suit pas ce régime. Cet article ne fait que signaler ce type de vente.

Une vente a l'essai est une vente dans laquelle l'acheteur doit utiliser le bien avant de décider d'acheter ou non le bien. Cet essai doit permettre a l'acheteur d'apprécier objectivement si les qualité du bien lui conviennent. Ce sont donc des périodes d'essai = en matière d'animaux (animaux de trait), en matière d'outils numérique (savoir si ça convient à l'entreprise), les véhicules (voiture, moto, etc). Durant l'essai il n'y a pas de vente, le bien reste la propriété du vendeur, mais c'est l'acheteur qui le détient. Si l'acheteur qui essaye le bien le casse, le détruit, ce n'est pas sa responsabilité mais celle du propriétaire. Il ne l'endosera pas en tant que propriétaire, mais en tant que fautif (resp civile délictuelle) sauf s'il l'essai a été contractualisé (loue des ski pour les essayer). Pendant cette période de prêt on organise l'utilisation du potentiel acheteur. Le vendeur, pour se protéger, peut contractualiser l'essai, le faire sous forme de contrat. Il peut aussi associer ce contrat d'essai a une promesse unilatérale de vente par exemple, il va s'engager a vendre si le client qui a essayé est convaincu. = conditions suspensives.

B - Promesse

- Promesse unilatérale : contrat préparatoire par lequel une personne s'engage a vendre ou a acheter.

-> Droit commun : Le bénéficiaire de la promesse obtient un droit d'option = donne du temps au bénéficiaire. Celui qui a promis est déjà engagé, mais celui qui en bénéficie dispose de temps, il ne sera engagé que s'il lève l'option. Ce temps de réflexion est utilisée en pratique, mais est aussi utilisé en dehors de ce temps de réflexion; on utilise la promesse dans le cadre du système des consignes. Le vendeur de la bouteille s'engage a racheter la bouteille une fois que l'acheteur l'aura fini. On l'utilise aussi dans le système du dépôt / vente.

Les promesses unilatérales sont souvent payantes. On peut faire payer au titre d'une indemnité d'immobilisation, le coût d'une immobilisation, car le vendeur ne peut pas vendre a quelqu'un d'autre. = il existe des contrats synallagmatique de promesse unilatérale.

La promesse, si elle se réalise, elle va entraîner la vente. Il faut donc que toutes les conditions de la vente soit réunies au jour de la promesse : il faut qu'elle existe, qu'elle soit déterminée ou déterminable, et pareil pour le prix. Il faut également que la capacité de la personne qui promet soit remplie. Il n'y a que le bénéficiaire qui ne s'engage pas.

Il n'y a pas de conditions de forme, sauf cas particulier, [art 1589-2 CC](#),

Pose des questions pratiques : la substitution par exemple : le bénéficiaire peut-il céder son option ? Oui, si les parties le prévoient.

Question aussi de savoir si on peut révoquer les promesses ? Tant que le délai n'est pas écoulé, le promettant est tenu de contracter (cf S3)

-> Régime spéciaux : la vente à la dégustation car le dégustateur a une option. Dans le code de la consommation il y a des promesses unilatérales spécifiques notamment en matière de vente immobilières. On trouve le même type de régime dans le code de la construction et d'habitation, dans le cas de vente d'immeubles à construire (on vend l'immeuble qui n'est pas encore construit).

- Promesse synallagmatique de vente : les deux parties sont réciproquement engagées. Il existe des situations où il y a des promesses unilatérales croisées. [Article 1589 du Code civil](#) qui dispose qu'un contrat synallagmatique de vente vaut vente. La JP a des positions qui sont assez factuelles. Parfois elle considère que les parties admettaient l'hypothèse d'une « non vente » = engagement synallagmatique.

[L'article 1589 du Code civil](#) dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix. Mais alors qu'elle est la différence entre une promesse synallagmatique de vente et une vente ? Lorsqu'on dit qu'une promesse syna vaut vente ça ne veut pas dire que c'est une vente, elle a juste les mêmes effets.

La JP n'applique pas de la même façon [l'article 1589 du CC](#). Il oblige le juge à analyser la volonté des parties, à aller au-delà de la simple appellation du contrat.

-> Certaines promesses syna sont de véritables ventes : une vente ferme (les parties se sont accordées sur tous les points du contrat, etc) une vente sous conditions suspensives, vente avec un terme (délais pour réaliser la vente). => la promesse est une vente

-> La promesse de vente est une promesse de réitération : elles révèlent leur intention de conditionner la conclusion du contrat de vente à un événement futur -> la partie veut tous les conseils du rédacteur de l'acte. L'article 1589 est ici utile. Le juge est autorisé à prononcer l'exécution forcée de la vente.

-> Une promesse syna autonome : lorsque les parties veulent que leur accord porte sur les éléments essentiels du contrat mais aussi sur les éléments accessoires au contrat (date de livraison, frais de livraison et taxes, etc) ces éléments sont essentiels pour les parties, alors que normalement elles sont secondaires. Si elles ne sont pas d'accord sur ces éléments, la vente n'aura pas lieu => cette forme de promesse syna exclut toute exécution forcée car si elles ne sont pas d'accord on peut pas réaliser la vente. Dans cette hypothèse là, la promesse syna ne vaut pas vente.

=> L'article 1589 du code civil est supplétif.

C - Le pacte de préférence

La partie s'engage à préférer un individu si un jour elle souhaiterait contracter. C'est un droit de préemption conventionnel. Le promettant ne donne pas son consentement au contrat futur. Il s'engage simplement à offrir une priorité d'achat s'il souhaite vendre / acheter mais il n'a aucune obligation de vendre ou d'acheter.

Il a des délais :

- Durée d'efficacité de la préférence : le promettant peut s'engager avec une durée déterminée, mais aussi avec une durée indéterminée. Si la durée est indéterminée, le promettant est tenu de respecter la priorité tant qu'il n'a pas proposé

au bénéficiaire.

- Durée laissé au benef pour se décider : il ne connaît pas le prix à l'avance. Le délai peut être précisé à l'avance, par exemple le bénéficiaire aura 2 mois pour se décider. Mais parfois la durée est indéterminée. Soit le juge le décide, ou alors on utilise le délais de prescription (5 ans).

Quand est-ce qu'on utilise des pactes de préférence ? Souvent dans des situations immobilières avec des ventes partielles = un proprio a tous les appart et tous les garages, et dit aux acheteurs que s'ils veulent revendre il va les acheter.

La sanction du pacte de préférence, prévu à l'article 1123 du CC.

CM4 : 28/01

Paragraphe 2 : La protection des consentements

Il y a un consentement qui est protégé dans le cadre de la formation du contrat de vente. Le but du CC est d'assurer que la rencontre des volontés soit faite de bonne manière : libre et éclairé

Le but du CC est que le consentement de l'acheteur soit donné de façon libre et éclairé. Mais il doit tout de même faire preuve de curiosité : il doit s'informer un minimum avant la vente.

A - Le consentement des parties

1) Le consentement protégé

Faut-il aller au-delà de la protection de droit commun ? (Vices du consentement). Le législateur et la JP ont pensé que dans certaines ventes il fallait aller au-delà de la protection du droit commun.

La JP d'abord a découvert puis étendu une obligation générale d'information (info précontractuelle). Elle a ensuite été consacrée par le législateur à **l'article 1112-1**

En matière immo il y avait un art 1238 qui imposait au vendeur d'informer sur les servitudes non apparentes, puis se sont ajoutées d'autres obligations : vérifications faites par des experts puis communiquées à l'acheteur (amiante, plomb, etc). Il y a aussi des textes qui imposent d'informer sur l'état antérieur du bâtiment.

Il y a aussi des dispositions spécifiques pour les lots de copropriétés par exemple.

Il y a ensuite la **loi Carrez** qui impose au vendeur de faire une expertise pour savoir combien il y a de mètres carrés.

Il y a aussi des précisions pour les ventes au consommateur qui imposent au vendeur une obligation d'info préalables renforcée.

2) le consentement forcé

Il existe des limites à la liberté contractuelle : des exceptions, qui viennent diminuer la liberté de choisir le cocontractant, de déterminer le contenu du contrat etc.

Ces exceptions sont données par le législateur avec l'ordre public économique et social qui dirige l'économie ou protège les parties.

Il y a des hypothèses de vente forcées (il n'y a pas d'exemple d'obligation d'acheter) : l'expropriation pour cause d'utilité publique. : **L'article 545 du code civil** = doit être fait dans le respect du droit constitutionnel. Ces garanties sont surveillées par le juge judiciaire.

Dans le code civil il y a aussi des articles moins connus : **art 661 du CC** : donne à tout proprio la faculté d'imposer à son voisin de vendre la moitié du mur mitoyen.

Question des voies de l'exécution : vente forcée des biens du débiteur, vente aux enchères généralement. On saisit les

biens du débiteur sans son accord pour les vendre. (en cas de prestation compensatoire, vente forcée d'un des biens de la personne)

On se pose la question du régime des ventes forcées. Dans ce type de vente, le vendeur n'est pas d'accord. Doit-il être garant des vices cachés de la chose ?

Parfois on peut aussi imposer un cocontractant. Le vendeur est d'accord pour vendre, mais on lui impose un cocontractant. :

- droit de retrait :

- litigieux : **article 1699 du CC** : débiteur cédé
- réunion des musées nationaux : après une vente aux enchères, la réunion des musées nationaux peut se substituer à l'acheteur
- l'administration fiscale : si une vente est réalisée sous le prix fixé, l'admin fiscale peut devenir l'acheteur
- droit de préemption

La sanction en cas d'irrespect du droit de préemption : nullité, substitution, réparation, etc

B - Les formes du contrat

En principe il n'y a pas de forme particulière à suivre pour la formation du contrat de vente. Mais en matière de certaines ventes il y a des formalités qui sont imposées : l'écrit par exemple, car permet de régler toutes les questions de preuve : donne une sécurité juridique.

Il faut bien discuter de la forme.

1) Formalité en matière immobilière

Formalité de la réalisation de l'acte authentique. Cette formalité est liée à la question de la publicité foncière. Si une vente est réalisée sans publicité foncière, la vente sera inopposable au tiers.

Il y a aussi des formalités particulières : mentions obligatoires : le diagnostic thermique amiantes etc est obligatoire dans l'acte, etc.

2) Les ventes mobilières

Dans les ventes mobilières il y a moins de formalité. Mais il y en a quelques-unes :

- ventes électroniques qui obéissent à des règles de formalités particulières (double clic)
- vente au consommateur
- vente à distance (droit de rétractation, etc)
- vente de bateau ou de navire, avion, etc le législateur impose l'écrit. Pareil pour la cession de brevets, de marque, etc.

Le législateur peut aussi imposer des mentions obligatoires. Par exemple la cession de fonds de commerce est très réglementée, sa forme varie bcp.

Section 3 : L'objet de l'accord de volonté

L'article 1583 du CC indique que la vente est parfaite entre les parties .. dès qu'on est convenu de la chose et du prix.

Paragraphe 1 : La chose

A - Existence de la chose

Elle doit exister : exigence logique mais elle a besoin d'exister matériellement, elle doit être juridiquement présente.

Parfois la chose a existé mais elle a été détruite : vente de la chose périmée. Traité par le **CC dans 1601 al 1 et 2 du CC**.

La vente de la chose future : la chose n'existe pas encore mais a vocation à exister.

=> il suffit juste que la chose soit déterminable : vente de chose à fabriquer (collier, chaise, vente d'une récolte à venir, etc)

Le législateur est intervenu pour certaines ventes de chose future : le législateur interdit la vente de toutes les œuvres futures à un éditeur (max 5). Il réglemente aussi la vente d'immeubles à construire.

La chose doit aussi être déterminée. Aucune difficulté lorsque la chose est un corps certain. Plus dur quand c'est une chose de genre. Un corps certain est une chose matérialisée, on peut le toucher, il est désigné. La chose de genre est une chose qui n'est pas individualisée, on voit un cahier de charge etc mais il existe des centaines de milliers de modèles. Par exemple tant qu'on a pas la chaise Ikea dans les mains on sait pas laquelle on va avoir.

Tant que la chose n'est pas individualisée elle n'est que déterminable, pas déterminée.

Il n'y aura de transfert de propriété que lorsque la chose de genre aura été individualisée.

L'individualisation de la chose va entraîner le transfert de propriété et mécaniquement le transfert des risques.

B- Appropriation de la chose

Pour que la chose puisse faire l'objet d'un contrat de vente : doit faire l'objet d'un droit de propriété + appartenir au vendeur.

impose de parler des choses hors commerce : qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de propriété

Art 1698 du CC. Il y a des choses hors du commerce qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de vente. Parce qu'elles sont illicites et vont donc rendre illicite la vente.

Ces choses hors du commerce sont mouvantes.

Mais il y a des choses qui sont quand même définitives : la personne humaine, sa liberté et sa dignité. + les choses relevant du domaine public + investiture politique (on peut pas vendre sa capacité d'électeur)

Pendant longtemps les clientèles civiles ne pouvaient pas être vendues (clientèles d'un médecin).

Une partie peut-elle faire sortir du commerce quelque chose ? La rendre inaliénable ? Oui, mais pas pour tout le temps : **art 900-1 du CC** : possible dans le cadre de libéralité.

La chose doit être appropriée par le vendeur. Le vendeur ne peut pas vendre une chose qui n'est pas à lui. Vente de la chose d'autrui, **art 1599 du CC** : la vente de la chose d'autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur ignorait que la chose était à autrui.

C'est une conséquence assez logique du principe d'immédiateté du transfert de propriété.

Sauf que **l'article 1583** n'est pas d'ordre public : on peut retarder le transfert de propriété. Ce qui compte c'est qu'au moment du transfert de propriété, la chose soit au vendeur. On peut donc vendre quelque chose qui n'est pas encore à nous. La vente de la chose d'autrui pose la question des ventes successives : vendeur qui soit propriétaire de la chose à un acheteur, puis cette même chose à un autre acheteur. => c'est la première personne qui a entre les mains la chose qui devient propriétaire (le premier publié pour les biens immeubles).

Paragraphe 2 : Le prix

Le prix est nécessairement une somme d'argent. Si pas d'argent, pas de vente. À ce prix on ajoute les accessoires :

Article 1593 du CC. La TVA n'est pas un accessoire du prix

Le prix doit aussi être déterminé (ou déterminable) : **article 1591 du CC**. On a la possibilité de confier à un tiers la tâche de fixer le prix. Le prix peut aussi être déterminé par des éléments pris à l'avance par les parties : profit réalisé par l'acheteur par exemple, ou alors le prix du marché au jour de la vente, etc.

Elles ont même la possibilité de dire que le prix sera celui du vendeur au jour de la livraison.

Question des ventes à l'euro symbolique, est-ce que c'est un prix réel et sans valeur ?

On peut vendre une chose sans valeur, donc possible de faire une vente à l'euro symbolique, mais si la chose a une grande valeur, l'euro symbolique n'est pas une vente (sauf si dette négative)

Il existe un principe constitutionnel : liberté du prix (sauf la baguette de pain, le livre ou certains médicaments).

Il y a aussi la question de la justice du prix : est-ce qu'il y a un rapport d'équivalence entre le bien et la valeur du prix ?

Oui, dans le CC il y a des dispositions qui sont là pour vérifier l'équivalence des prestations.

Section 4 : Les effets de la vente

Paragraphe 1 : Les effets réels

Le premier est le transfert de propriété : organisé par le code civil.

A - Transfert de propriété

- Organisé par le code civil : le transfert de propriété se fait solo consensus (par le seul effet du consentement). Le transfert réel se fait sans l'intervention du vendeur. Conception évoluée qui dissocie le droit et la chose.

B - Transfert des risques

Les risques pèsent sur le propriétaire. C'est le principe du droit français, exprimé à l'art 1196 du CC.

Quand il y a vente avec transfert de propriété immédiat, au moment de la vente, les risques sont transférés directement, même si la chose n'est pas encore dans ses mains. On peut en revanche retarder le transfert de propriété.

Si la vente est annulée, l'annulation a un effet rétroactif, et le vendeur n'a jamais cessé d'être propriétaire. Il va devoir rendre la chose. Mais si elle a disparu ?

Exception : individualisation de la chose qui arrive plus tard ou question du retard (la propriété va revenir sur le vendeur pour pouvoir le sanctionner, car en retard de l'obligation d'exécution)

Paragraphe 2 : Les effets personnels

A- Les obligations du vendeur

Le vendeur a une obligation d'explication : il explique à quoi il s'oblige.

Article 1603 du CC

Le vendeur a deux obligations principales :

- délivrer
- garantir la chose
- > obligation du vendeur : conseil, sécurité, etc
- > Obligation de délivrance : article 1604 du CC : mise à disposition de la chose de façon conforme aux stipulations

1) Obligation de délivrance

contractuelles.

CM5 : 2/02

Cette obligation de délivrance n'est pas une obligation de livraison. C'est une obligation qui impose de mettre à disposition de l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles

-> ***différence entre conformité de la chose et la chose qui est atteinte d'un vice caché.***

Critères de distinction :

- La chose non conforme : différence entre les stipulations contractuelles qui décrivent la chose et la chose concrètement qui est remise à l'acheteur. C'est un critère matériel, mais subjectif, car dépend des stipulations contractuelles. On parle alors de « aliud ». C'est la non-conformité.

- Le vice caché : défaut sur la chose qui la rend impropre à son usage normal. Elle a l'air de correspondre à la chose, donc conformité, mais c'est une chose amoindrie, c'est le « pejus ». C'est pas un critère matériel mais un critère fonctionnel.

Ex : Ordinateur avec une certaine puissance et on nous donne un ordinateur avec une autre puissance : ne correspond pas aux stipulations contractuelles = problème de conformité

En revanche, on nous livre des tuiles, pour se protéger des intempéries mais elles ont un défaut : elles ne résistent pas au gel, et donc elles cassent. Elles ne répondent pas à leur usage normal = vice caché.

En pratique, la différence entre ces deux notions est très difficile à discerner. Or, c'est embêtant car régime juridique différent : délai de prescription (5 ans et 2 ans).

Il y a une interdiction de cumul des deux (on ne peut pas invoquer la non conformité + le vice caché.

Source de litige importante : en matière de vente à la consommation on a écarté la différence entre les 2 on parle que de non conformité.

Un projet de réforme propose aussi un alignement entre les 2 régimes.

Mais pour l'instant cette distinction entre les 2 existe, avec des régimes juridiques différents.

-> ***question des accessoires*** : **L'article 1615 du CC** impose de délivrer la chose ainsi que ses accessoires et tout ce qui est utile à son usage perpétuel.

Accessoires :

- accessoires produits par la chose : fruits. Si on vend un appartement qui crée des loyers, les loyers sont le fruit de la chose.
- accessoires affectés au service de la chose : on achète une voiture, mais aussi le cric, la roue de secours, la carte grise, etc.

Ces accessoires vont devoir être compris dans la délivrance de la chose. Cela peut aussi être une servitude par exemple, mais également un contrat (en principe non, ils ne sont pas cédés avec la chose) c'est le cas en matière d'immeuble qui est déjà soumis à un bail, le bail est un accessoire de la chose, il est vendu avec. Idem pour les cessions d'entreprise, les contrats de travail suivent.

-> ***Question du lieu*** : c'est là qu'on comprend que la délivrance n'est pas une livraison : en principe c'est à l'acheteur de venir retirer la chose.

C'est donc l'obligation de ne pas empêcher l'acheteur de venir retirer la chose.

Ce principe est supplétif : on peut très bien mettre sur la tête du vendeur la charge d'apporter la chose.

Aussi, parfois le retraitement de la chose ne se fait pas systématiquement au domicile du vendeur. Par exemple, l'immeuble est représenté par les clefs pour la remise. Pour les arbres, les animaux, la délivrance se fait par un marquage.

-> **Question du délai** : quand après la conclusion du contrat. Dès la signature du contrat, ou après.

La délivrance va se faire éventuellement après, mais dans un délai raisonnable, et vaut mieux le fixer par contrat (les professionnels sont obligés de le préciser).

-> **Question de l'inexécution** : **article 1610 et 1611** prévoient cette sanction. L'acheteur a une option : il peut soit demander l'exécution forcée soit la résolution du contrat. Dans les 2 cas il a le droit à des dommages-intérêts qui sont conditionnés à l'existence d'un préjudice.

Il existe des subtilités selon la sous-catégorie de vente : vente au consommateur, etc

2) Les garanties du vendeur

Les garanties ne sont pas une obligation. Dans la garantie il y a une automaticité. La faute n'est pas un problème, on ne se pose pas la question. La garantie est automatique. Le vendeur a 2 garanties :

- **éviction** : **art 1626 et suiv du CC** ->

- la garantie contre l'éviction impose au vendeur une **garantie de son fait personnel**, il ne doit pas évincer l'acheteur de son fait personnel. Il est prévu par **l'art 1628**, prévoit une garantie perpétuelle.

° Le vendeur garantit l'acheteur contre les **troubles de droit** qui seraient du fait du vendeur. (vendeur qui vend un immeuble, cet immeuble est dit libre de droit donc sans locataire, mais le vendeur se présente le jour de la vente avec un contrat de bail. = trouble de droit.).

° **Troubles de fait** : un vendeur qui vient harceler l'acheteur pour lui demander si l'immeuble lui plaît. Le vendeur doit s'empêcher d'aller voir son ancien appartement. = actes qui portent atteinte à la jouissance du bien par l'acheteur

- **garantie du fait des tiers** : cela dépend. Si c'est un trouble de droit il doit garantir, mais ça n'est que supplétif, il faut que ce soit stipulé dans le contrat.

- **garantie le trouble de fait des tiers** : par exemple un voisin chiant. Le vendeur n'est pas censé garantir le comportement des voisins (sauf s'ils ont un lien).

=> les effets de la garantie sont prévus par **art 1630 du CC** : on prévoit une indemnisation, par principe des dommages et intérêts. Selon les choix de l'acheteur, on va prévoir la résolution du contrat, ou alors on continue la vente mais on diminue le prix (remboursement partiel).

- **vices cachés** : le vendeur est garant des éventuels vices cachés qui viennent diminuer la chose. Elle porte non pas sur la possession de la chose, elle conserve son bon usage. Or, le vice est le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel il est destiné. Cet usage est ordinaire, habituel, c'est une notion objective, pas subjective. Si on avait prévu pour la chose un usage spécifique, on tombe du côté de la chose conforme. Là on parle d'attendu normaux, ordinaires. Aussi, la garantie du vendeur ne porte pas sur tous les vices, mais sur les vices cachés. L'acceptation du contrat est censée purger les vices apparents. Par contre les vices cachés ne sont pas purgés par l'acceptation. C'est le vendeur qui est présumé être la personne la mieux placée pour informer l'acheteur.

Le vice caché n'est pas le vice dissimulé (on ne parle pas de réticence dolosive). Même s'il est de bonne foi, il est garant.

Le vice caché est celui qu'un acheteur ne pouvait pas voir.

Le caractère caché du vice s'apprécie en la personne de l'acheteur (appréciation in concreto). Mais comment faire lorsqu'il y a eu une succession de vente, et que le dernier acheteur se rend compte du défaut. Le caractère caché du vice s'apprécie selon l'acheteur intermédiaire (le premier).

Il existe un régime légal, une garantie légale, qui impose au vendeur cette garantie contre les vices cachés, mais ce régime est supplétif. On rencontre donc des régimes conventionnels.

Le régime légal est relativement simple : il y a un délai de prescription de 2 ans + sanctions objectives prévues : c'est l'acheteur qui a l'alternative : action rédhibitoire (résolution) ou action estimatoire (réduction du prix)

Le choix de l'acheteur s'impose au juge.

Exception :

- vente forcée : Les ventes faites par autorité de justice ne sont pas soumises à la garantie du vice caché. **Article 1649 du CC**
- vente des animaux domestiques : ne sont pas non plus soumis à la garantie du vice caché.

Les aménagements conventionnels : les parties peuvent prévoir une autre forme de garantie.

- limiter la garantie : clauses limitatives mais que si le vendeur est de bonne foi. (vices cachés inconnu du vendeur) **article 1643 du CC**
- accroître la garantie : clause d'extension de garantie : légal. Le vendeur peut s'obliger à garantir +, et + longtemps. Attention, parfois il y a de fausses clauses d'extension de garanties. Réglementation dans le code de la consommation.

B - Obligation de l'acheteur

L'acheteur a deux obligations :

- retirer la chose
- payer le prix : le prix est exigé qu'au moment de la délivrance. Difficulté de compatibilité avec l'article 1612.

Le législateur fixe un délai de paiement maximum.

Cette obligation implique de payer le prix + les accessoires. Mais l'art 1593 CC est supplétif (les parties peuvent préciser que les accessoires sont compris dans le prix).

Selon l'art 1651, le paiement se fait au lieu où doit se faire la délivrance. Si rien n'est prévu, la délivrance se fait au domicile du vendeur.

L'acheteur doit retirer la chose : l'obligation de délivrance est une obligation de ne pas faire, et la c'est une obligation de faire. C'est à l'acheteur d'aller retirer la chose. Ainsi, si'il y a des frais pour retirer la chose c'est à la charge de l'acheteur.

Si l'acheteur refuse de retirer la chose : il ne peut pas refuser.

On a permis au vendeur un mécanisme de destockage. Vider leur stock à partir d'un délai prévu dans le contrat.

Chapitre 2 : Autres contrats translatifs de propriété

Section 1 : Les contrats de transfert définitif et immédiat de propriété de la chose

Paragraphe 1 : Le transfert immédiat

Le contrat d'échange : dérivé du contrat de vente, modalité du contrat de vente. Sur le plan historique, on aurait pu parler de l'échange en premier, c'est le contrat le plus ancien.

L'échange est une vente frustrée car il n'y a pas d'argent. C'est le troc, un mode de circulation des richesses primitif.

Toutefois c'est très utilisé dans le commerce international (cession de créance contre un immeuble, échange de titre de société, etc). Très pratiqué car : évite le problème des taux de change + embargo de monnaie (monnaie qu'on ne peut pas utiliser ailleurs que dans un seul pays)

On appelle l'échange la compensation

A- Le contrat d'échange

L'échange est un contrat synallagmatique et commutatif. Ce n'est pas parce qu'il y n'y a pas de prix au sens d'argent que ce n'est pas un contrat onéreux.

C'est l'**art 1702 du CC** qui donne la def « les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».

L'échange n'est qu'une sorte de vente : pas de prix avec une contrepartie en nature. Mais enft non car pas d'argent.

C'est deux transferts de propriété, mais sans prix.

Attention, il y a des ventes avec une dation en paiement : payer par un autre moyen que de l'argent, mais c'est bien une vente car au départ il y avait un prix. (tu paye le resto avec ta montre).

Il y aussi une soulte = ??

Le régime est gouverné par un principe d'assimilation à la vente, exprimé par l'**art 1707 du CC** : « toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'applique d'ailleurs à l'échange ». Attention, cela veut dire implicitement qu'il y a des règles implicites qui sont spécifiques au contrat d'échange.

- Règles reprises de la vente : règles qui concernent le consentement, l'objet et les garanties sont celles de la vente

- **consentement** : l'échange fonctionne selon le consensus (il faut être d'accord sur le principe); attention parfois il peut y avoir des échanges forcés du fait de la loi, notamment en matière rurale.

- **question des garanties** : attention, ici les deux sont vendeurs et acheteurs, elles doivent les garanties du vice caché et d'éviction. Lorsqu'il y a une éviction entre les copermutants (pas échangiste) il a le choix de continuer à conclure et le choix de rendre la chose en mettant fin au contrat d'échange.

- **résolution** : en cas d'inexécution, ce sont les sanctions de droit commun qui sont prévues, avec la possibilité pour les 2 copermutants d'agir en résolution du contrat d'échange.

- **la lésion** : peut-il y avoir une action s'il y a un déséquilibre manifeste entre la valeur des deux biens ? Non, car il n'y a pas de prix. La lésion est une technique qui n'intervient que s'il y a un prix.

- Règles spéciales : le prix, la préemption sont des règles spéciales.

Possibilité de conclure des pactes de préférence.

B - L'apport en nature en société

La société est un rassemblement d'associés qui mettent des choses ou de l'argent en commun, avec lesquels ils vont créer une personne morale qui a un but. Une société commence à partir du moment où des personnes apportent quelque chose à la personne morale. Ils doivent faire un apport. Il y a l'apport en numéraire (argent) l'apport en industrie (force de travail) et l'apport en nature (propriété d'un immeuble qui va l'apporter à la société) et va recevoir en contrepartie des parts sociales. L'apport est un transfert de propriété. Le bien en nature apporté à la société va sortir du patrimoine de la personne pour entrer dans le patrimoine de la société.

Ce n'est pas une vente : transfert de propriété contre des parts sociales

Il est prévu par le code **article 1843-3 du CC**. Assimilation assez forte avec le contrat de vente : garantie de l'apporteur. Mais ce n'est pas un contrat de vente : les dispositions spécifiques à la vente ne s'appliquent pas en cas d'apport en société.

La dation en paiement : prévu par **l'article 1342-4 du CC** : le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. Le prix qui était dû est réglé par autre chose qu'une somme d'argent. C'est une façon de payer autrement. Il y a bien des garanties (???) suite)

C'est un contrat extraordinaire : on ne fait pas ce qui était prévu à l'origine. C'est un paiement valable mais normal. On ne peut pas le remettre en cause, en principe, sauf en cas de procédure de redressement judiciaire. La dation est considérée comme nulle en cas de redressement judiciaire.

CM6 : 11/02

Paragraphe 2 : Le transfert retardé

On utilise des bribes contractuelles pour arriver au final à un transfert de propriété. On trouve des mécanismes simples comme :

- contrat cadre et contrat d'application ; on les retrouve dans les **contrats de distribution**. Ils sont construits sur la base d'une architecture intégrée depuis 2016 dans le CC. L'idée est de formaliser une relation d'affaire sur le temps, long mais dont on sait pas à l'avance le volume, le rythme. On fait un contrat cadre pour gérer le temps long, tout ce qui peut être prévu à l'avance. Ensuite, on fait des contrats rapides, des contrats d'application pour adapter le contrat au fur et à mesure. = **Article 111 du CC**

On trouve d'autres formules inventées par la pratique mais pas encore intégrées dans le droit commun.

- Contrat de location - vente :

- contrat de location - accession (leasing)

-> Adjoint la vente et le bail. Cela participe d'une opération de crédit : on va associer un bail à une vente de manière à ce qu'une personne utilise une chose dont elle a besoin maintenant, mais permet de capitaliser.

Lorsqu'on capitalise, il peut y avoir dans le patrimoine, à la fin de l'opération, un capital (chose qu'il n'y a pas lorsque on loue un appartement par ex). Au bout d'un certain moment on aura la possibilité d'acquérir le bien qui est déjà utilisé mais pour une somme qui tient compte de ce que l'on a déjà payé.

C'est comme un crédit mais c'est un moyen différent lorsqu'on a pas de garantie. C'est une forme de location financière.

-> Vente avec un transfert de propriété retardé par une clause pénale : vente assortie de conditions et différents termes pour échelonner le paiement.

-> Bail avec promesse unilatérale de vente : le locataire peut soit lever l'option et devenir acquéreur de la chose, soit abandonner.

=> Quand on propose ça a un consommateur on considère cette opération comme un prêt, avec les mécanismes propres au prêt (code de la consommation).

Attention : pas confondre le leasing avec **leasback**. Cession de baux opération financière utilisée par les entreprises qui ont besoin de trésoreries et n'ont que les biens immobiliers offerts en garantie. Elles peuvent mettre l'immeuble sous hypothèque, ou peuvent utiliser le leasback : vendre l'entrepôt à la banque qui va le louer à cette entreprise. La location va être associée à une promesse unilatérale pour qu'au bout d'un moment on puisse racheter l'entrepôt en payant un prix résiduel.

On a le même schéma avec la **location accessions** : porte sur un bien d'habitation. On prévoit de devenir acquéreur mais comme on n'a pas encore assez d'argent on paye des loyers pour ensuite être propriétaire. Loi qui va protéger le locataire : on demande à ce que le contrat de location soit passé de façon authentique (devant notaire).

Il y a un 3^e schéma : le **contrat de crédit bail** : beaucoup utilisé dans le monde des affaires et ainsi intégré dans le code monétaire et financier. Contrat commercial qui permet de financer des outils, du matériel ou des immeubles à vocation commerciale ou fond de commerce. Il ne peut être conclu que par un établissement de crédit (une banque). Commerçant qui a besoin d'un matériel, n'a pas l'argent pour l'acheter direct, pas assez de garantie pour crédit. Donc crédit bail ; la banque va acheter le matériel, elle devient propriétaire d'un bien qui lui a été désigné par le client, va lui louer et il pourra ensuite l'acheter en payant un prix résiduel. Mandat à la banque pour acheter le bien + achat + location + promesse unilatérale d'achat + transfert de propriété.

La propriété joue le rôle de sûreté du remboursement. Opération tripartite car rentre dans l'opération le premier vendeur.

Section 2 : Transfert de propriété temporaire

Le droit de propriété a la particularité (art 544 du CC) d'être perpétuel et le plus absolu qui soit = on peut faire ce que l'on veut avec sa chose (usus, fructus et abusus). Comment réaliser un transfert de propriété temporaire ?

- **Le bail emphytéotique** : ils ont vocation à durer longtemps : pendant cette durée il y a comme un transfert de propriété.

Prévu aux art L451-1 et suiv du code rural et de la pêche maritime. Il en existe plusieurs types mais portent nécessairement sur un immeuble et assure à l'emphytéote (le locataire) un droit réel (un droit sur la chose) et pas un droit personnel. Ce droit réel suppose d'avoir la maîtrise de la chose en contrepartie d'un « canon » (genre de loyer ou redevance), généralement modique car le but est d'encourager l'emphytéote à exploiter le bien. C'est généralement sur des terrains agricoles : il faut exploiter les terrains car sinon ils perdent de la valeur. C'est un moyen différent que la location car extrêmement coûteux au vu de l'activité à entretenir. Là c'est un bail avec un loyer modéré, mais avec une durée suffisamment longue qui permet à celui qui a investi de rentrer dans ses investissements.

Toutefois cette durée longue entraîne des questions : les grosses réparations, la responsabilité etc.

=> C'est un acte de disposition, il obéit aux règles de la publicité foncière, c'est un contrat que l'on enregistre. Il donne à l'emphytéote tous les droits du propriétaire, comme le droit d'accession, les servitudes, etc.

Toutefois, il n'est pas un propriétaire. À la fin du bail doit rendre la chose, qui revient dans le patrimoine du bailleur (avec toutes les améliorations de la chose).

-> Durée minimum : 18 ans

-> Durée maximum : 99 ans

-> Normalement un contrat a titre onéreux.

-> Transmet un droit réel : le proprio d'origine, le bailleur, doit des garanties comme un vendeur (éviction et vices cachés)

- **Le bail a construction / réhabilitation** : L251-1 et suiv du code de la construction et des habitations. Proprio d'un terrain ou immeuble qui n'est plus en très bon état. Location d'un terrain a quelqu'un qui va louer le terrain et faire un investissement pour construire qlqch. On va laisser le temps au locataire de profiter de son investissement = bail très long. On va organiser une transmisison de propriété, un droit réel. A la fin du contrat il devra rstituer le terrain tel qu'il est

-> Durée minimum : 18 ans - maximum 99 ans

- **La fiducie** : nouveau en droit français. Intégré dans l'art 2011 du CC. C'est un contrat nommé qui met au prise 3 perosnnes : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. Contrat par lequel le constituant transfere au fiduciaire la propriété de tout ou partie des biens qu'il possède. A charge pour le fiduciaire d'agir dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Ce contrat se base sur le droit anglo-américain : le Trust. Cette acclimattaion a été faite en 2007. L'idée est originale pour le droit français : on a créé un patrimoine séparé, affecté, le patrimoine de la fiducie. Le fiduciaire se retrouve a la tête de 2 patrimoine : le sien et celui de la fiducie. (jusque là un patrimoine était pour une personne). Nécessite un regime juridique précis :

-> la formation du contrat de fiducie : le régime est stricte, ce n'est pas un contrat comme les autres. Il doit être conclu par écrit, doit contenir des mentions obligatoires art 2018 du CC, doit être dans certains cas conclu par acte notarié. Peut etre une personne physique ou morale. Possibilité d'utiliser dans le cadre d'une gestion de patrimoine, mais pas dans le cas d'une transmission de patrimoine. Les parties ont une certaine liberté quand à la durée, mais doit pas dépasser 99 ans. Les parties ont aussi une liberté quant a l'administration fiduciaire. Il y a toutefois un enregistrement a faire au service des impôts, car on veut donner une date certaine a l'acte. Si dans le patrimoine fiduciaire il y a des immeubles il faut une publicité foncière.

-> les effets : les pouvoir et les missions doivent être clairement définies. Il doit agir selon la misison qui lui a été confiée et au bénéfice du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut etre le constituant, le fiduciaire ou un tiers. Pour réaliser ces missions le bénéficiaire est astreint a des obligations comptables rigoureuses, c'est une gestion exigée de lui. Il doit rendre des comptes. Il a des pouvoirs (de gestion) c'est lui qui a les pouvoirs les plus étendus, mais ses pouvoirs sont déterminé par le contrat de fiducie. S'il doit répondre de ses actes qui outrepasse ses pouvoirs sur son propre patrimoine.

-> Création d'un patrimoine supplémentaire : le patrimoine d'affectation. Ce patrimoine est affecté mais pas a une personne morale (dans le cas d'une société par exemple). Ici, le patrimoine est affecté a une personne physique, le fiduciaire. Cela pose des questions : le fiduciaire a des créanciers, est-ce qu'ils peuvent aussi saisir le patrimoine affecté ? Les créanciers ne peuvent pas saisir le patrimoine affecté, ils doivent se cantonner au patrimoine perso. Se sont des patrimoines distincts.

Les créanciers qui vont saisir le patrimoine affecté mais il n'y a pas assez de fonds : ils peuvent saisir le patrimoine personnel du fiduciaire. On peut toutefois prévoir des clauses spéciales et les faires accepter aux créanciers : le droit de poursuite ne pourra s'effectuer que sur le patrimoine restant du constituant.

Les biens qui constituent le patrimoine affecté peuvent tjr être utilisé par le propriétaire.

-> Fin du contrat : en cas de décès du constituant, arrivé du terme, avant le terme si le but poursuivi est atteint, ou encore lorsque tous les bénéficiaires renoncent a la fiducie. Enfin, il peut aussi y avoir la liquidation judiciaire du contrat de fiducie qui mettrait fin au contrat. On assimile cette hypothèse a l'absorption du fiduciaire (car question d'intuiti personnae), idem si le fiduciaire a une interdiction de gérer.

Lorsqu'il y a la fin du contrat différentes hypothèses : si décès du constituant les biens reviennent au constituant (a la succession), si but atteint beneficiaire récupère

- **Convention de portage** : Technique utilisée en droit des sociétés. Opérateur qui a envie d'être propriétaire d'une action d'une société, mais pas les moyens. Il va s'adresser à une banque en lui demandant d'acquérir des actions pour lui donner la certitude d'en être propriétaire plus tard. Idem, un vendeur (une personne qui devient Premier ministre et qui ne peut plus être propriétaire d'une entreprise, on cède l'entreprise à l'établissement de crédit qui va amener à la vente).
Mécanisme : il faut un mandat dans l'opération, une cession, promesses, établissement de crédits, etc.
Permet d'éviter le recours à la convention de gage (quelqu'un qui se porte acquéreur des biens)

Titre II : Contrat portant sur l'usage d'un bien

L'objectif est d'utiliser le bien : bail et prêt. Entraîne la mise à disposition temporaire + obligation de restitution. Toutefois, il n'y a pas de régime juridique de cette obligation de restitution dans le Code civil, idem pour la mise à disposition.

Dans le contrat de dépôt il y a une restitution. Sauf que pour le dépôt il n'y a pas d'obligation de mise à disposition (il n'est pas censé utiliser la chose, juste la garder).

Chapitre 1 : Le bail

Section 1 : Le droit commun du bail

Définition donnée par le CC à l'**art 1709**, il appelle ça le louage des choses : contrat par lequel une des parties s'engage à mettre à disposition d'une autre, temporaire, à titre onéreux (il y a une somme d'argent), et il y a un droit personnel du locataire contre le bailleur (il a le droit d'exiger la jouissance du bien). En face il y a un locataire, le preneur à bail. Le bien loué est un bien incorporel : on parle de licence.

La caractéristique du contrat de bail est de donner naissance à un droit temporaire et personnel. C'est la différence avec la vente car la c'est temporel. Dans le contrat de bail il y a aussi la restitution, chose qu'il n'y a pas dans la vente. Dans le bail, il y a quelqu'un qui jouit d'une chose, mais l'utilisation de la chose est limitée, par exemple il ne peut pas détruire la chose.

Différence entre bail et contrat de coffre-fort : c'est un contrat que l'on passe avec la banque pour avoir dans la banque un coffre avec nos affaires personnelles. Toutefois, on a pas une jouissance suffisante du coffre-fort, il faut la présence du banquier, etc, on a pas la jouissance illimitée, c'est donc pas un bail. Le contrat de bail est onéreux, il faut un prix, une somme d'argent. Il y a des baux qui en fait n'en sont pas : le bail à nourriture (contrat par le lequel la jouissance d'un immeuble est cédée en échange de soigner, nourrir etc le bénéficiaire).

Les sources du contrat de bail : **article 1713 à 1778 du CC**. Le contrat de bail connaît une hyperspécialisation. Il y a des contrats spéciaux pour les baux les plus utilisés, comme le bail d'habitation, le bail rural, etc. Le code civil prévoit des règles qui sont par principe supplétives, mais ne s'appliquent qu'à certains types de baux.

CM7 : 18:02

Paragraphe 1 : La formation du bail

Le bail est régi par les règles du Code civil mais ce contrat fait l'objet de réglementations hors du Code civil. Pour la formation de ce contrat, il est possible à l'instar de la vente, d'utiliser des avant-contrats : pacte de préférence et promesses.

A- Les règles de fond

A ce contrat, il faut un objet. C'est le principe de droit commun des contrats : il s'applique dans le bail avec des spécificités.

Il y a d'abord la chose : étant précisé qu'à l'instar de la vente, le bail peut porter sur toute forme de bien ; des biens corporels comme incorporels (1713).

Dans l'hypothèse de celui qui mettrait en location une chose qui n'est pas la sienne : est-il possible de passer un bail sur la chose d'autrui ?

Pour signer un bail, il n'est pas indispensable d'être le véritable propriétaire du bien, car louer quelque chose ne revient pas à en céder la propriété.

La difficulté c'est quand le locataire voit sa jouissance troublée par le véritable propriétaire ; le locataire peut agir contre le bailleur en lui disant que ce bailleur ne garantit pas la bonne jouissance de la chose.

Dans ce cas, le bail n'est pas opposable au propriétaire. C'est l'hypothèse où le propriétaire n'est pas d'accord avec le bail ; il peut donc expulser le preneur.

- Une « **fausse exception** » : se rendant compte que le bailleur n'est pas le propriétaire, le réel propriétaire peut confirmer ce bail et s'interdit d'expulser le preneur.

- **La deuxième exception** c'est la **théorie de l'apparence** : le preneur peut rester dans les lieux s'il plaide la théorie de l'apparence : c'est le cas où le bailleur qui n'est pas le vrai propriétaire fait louer le bail en se faisant passer pour le vrai propriétaire. Là, on tient compte de l'apparence en ignorant volontairement la réalité. Si le preneur est de bonne foi et qu'il croyait véritablement aux pouvoirs du bailleur, le bail est opposable au propriétaire. C'est au propriétaire de faire attention, de se rendre compte de ce type de situation. La théorie de l'apparence vient lui rendre le bail opposable. Dans ce cas il devient bailleur comme véritable propriétaire. Pour que cette théorie fonctionne, il faut qu'il y ait eu une erreur légitime et donc de bonne foi de la part du preneur.

1) L'objet du bail

- La chose : Dans le cas où la perte de la chose louée par cas fortuit et pas par la faute du bailleur ; aucune des deux parties n'est responsable de cette perte. **L'article 1722** dit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Cet article s'applique naturellement aux choses corporelles. Mais il peut s'appliquer aussi aux bien incorporel

- Le prix : C'est un élément très important parce qu'il est un élément de définition et donc de qualification ; mais quel prix ? Comment on fixe le prix dans un contrat de bail ?

Il faut que le prix soit déterminé ou déterminable comme n'importe quel prix dans n'importe quel contrat. En pratique, le loyer est fixé par la convention des parties.

Comment peuvent-elles faire ?

- Elles le font avec un **forfait qui d'étend par période** : s'il y a plusieurs périodes, ça va être tant par un mois, deux mois, trois mois.

- Mais on peut aussi fixer un **loyer variable** qui va varier en fonction de différents critères mais qu'ils soient fixés de manière identifiable et objective et pas au bon vouloir du preneur ou bailleur.

- On peut également appliquer une variable (indice d'indexation) ; un loyer variable qui dépend de différents critères comme le **forfait indexé** : on parle de **clause d'indexation** ; on va prévoir par cette clause que le loyer va varier en fonction de la variation d'un index ; par exemple, l'index du coût du blé ou encore l'index du coût de la construction.

Le droit français impose des règles particulières quant au choix de l'indice ; il faut que ce dernier respecte des conditions : il faut que l'indice soit en rapport avec l'activité de l'une des parties ou avec l'objet du contrat. Si ça n'est pas le cas, l'indice est déclaré nul (juste la clause d'indexation, pas le loyer qui va par conséquent, rester fixe).

Il faut faire attention quand on choisit cet indice. Par exemple, sur les baux immobiliers, on utilise l'indice du coût de la construction.

2) La durée du bail

Etant donné qu'il y a une obligation de restitution à la fin, se pose la question de la durée qui est un élément essentiel du contrat de bail sans lequel ce dernier ne peut pas exister.

Le contrat de bail est un contrat à exécution successive. Il faut une durée qui peut être très courte : des locations saisonnières, des locations qui durent une matinée. Ce qui compte c'est que pendant cette durée même très courte, il y ait une jouissance stable.

Il faut avoir la certitude que le bail ira jusqu'au bout : le preneur ne doit pas être à la merci du bailleur. Si le bien est loué pendant deux heures, le preneur ne peut pas être troublé dans sa jouissance.

Si le bailleur loue pour un an mais qu'au bout d'une semaine, il demande au preneur de partir, le contrat perd son caractère stable ; la jouissance n'est donc pas stable. Sinon, le contrat est requalifié en convention d'occupation précaire ; ça ressemble à un bail mais ça n'en est pas un parce que la jouissance n'est pas stable.

- Détermination de la durée : Le Code civil opère une distinction ancrée dans le droit français : Le CDD et le CDI. Ce qui compte pour la durée, c'est la stabilité que ce soit déterminé ou indéterminé.

- **Le CDI** : Le Code civil parle de « bail sans écrit » ; ça veut juste dire que la durée est indéterminée, rien de plus. Dans ce bail à durée indéterminée, il est prévu que chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatérale discrétionnaire. Chacune des parties peut sortir du bail de manière unilatérale. Ce droit de résiliation doit respecter des conditions, en particulier, un préavis. Un préavis qui peut être fixé dans le contrat ou alors il doit être d'une durée raisonnable. Cette règle de résiliation est d'ordre public parce que les engagements perpétuels sont prohibés dans le droit commun des contrats. Si les parties le mettent dans le contrat, c'est un motif de nullité absolue.

- **Le CDD** : Le Code civil l'appelle le « bail par écrit ». Cela signifie que dans les obligations du bail, il y a un terme. On adjoint aux obligations du bail un terme qui peut être certain comme incertain. Le terme est un événement futur et certain. On l'oppose à la condition qui est future et incertaine (c'est un aléa). Dans le terme, la date peut être certaine mais peut aussi être incertaine ; un événement futur et certain mais dont la date est incertaine. Quand il y a un terme, le CDD cessera le jour du terme sans la moindre notification de donner congé. Il arrive toutefois que malgré l'arrivée du terme, le preneur se maintient dans les lieux.

Dans ce cas, on a deux hypothèses :

- **Les parties sont d'accord** : on a alors un renouvellement du bail ; c'est un nouveau contrat. Il peut y avoir un accord tacite ou expresse. Quand il y a un accord tacite, on n'a pas les détails du nouveau contrat mais juste la volonté de continuer, le bail continue sous les mêmes conditions mais le CDD se transforme en CDI (1738) ;
- **Les parties ne sont pas d'accord** : on peut forcer le preneur à une restitution et/ou à une expulsion.

- Stabilité de la jouissance : **L'article 1743 du Code civil** dispose que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail. Cet article ne s'applique qu'aux locations immobilières.

Pour faire simple, cet article prévoit que si le propriétaire vend le bien loué, le nouvel acheteur n'a pas le droit d'expulser le locataire (qu'il s'agisse d'un fermier, d'un métayer ou d'un locataire classique) dès lors que le bail a été rédigé par un notaire ou qu'il possède une date officielle incontestable.

Cependant, pour les locations qui ne sont pas des exploitations rurales, l'acheteur conserve le droit de donner congé au locataire si une clause spécifique a été prévue à cet effet dans le contrat de bail initial. Cette règle ne concerne que les locations de biens immobiliers. Le bail s'impose donc au nouveau propriétaire, qui est obligé de reprendre le contrat et de le poursuivre aux mêmes conditions.

Même si la loi exige un acte officiel pour éviter les fraudes, comme la création de faux baux antidatés juste avant une vente, les juges se montrent très souples dans leur interprétation. L'objectif principal est de débusquer les tricheurs ; dès lors que l'on peut prouver la réalité de la location, même sans acte notarié, cela suffit pour que le locataire soit protégé et puisse rester dans les lieux.

Si un décès de l'une des parties survient pendant la durée du bail, ce décès entraînerait la fin du contrat. Mais le contrat de bail n'est pas un contrat intuitu personae, donc la mort ne met pas fin au contrat de bail. **L'article 1743** dispose que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Le contrat tombe dans l'indivision successorale ; il est transmis aux héritiers. Dans beaucoup de statuts spéciaux, le preneur dispose de ce droit de renouvellement. En plus de la stabilité, on veut s'assurer qu'il pourra se renouveler.

B - Les règles de forme

En principe, il n'y a pas de forme ; on obéit au principe du consensualisme. Mais ce droit commun est dépassé par tous les droits spéciaux. A **l'article 1714** sont évoquées quelques exceptions.

Le principe du consensualisme c'est qu'il n'y pas de forme **ad validitatem**. Si une loi impose une forme ad validitatem, cela veut dire que si on ne respecte pas une forme précise (un écrit, un acte notarié), le contrat est nul et n'existe pas aux yeux de la loi. Dans le consensualisme, le principe c'est que cette logique de formalité n'existe pas.

L'article 1715 dit que « si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données ». Pour traduire cet article, quand le bail n'a pas d'écrit, ça va être très compliqué de le prouver surtout si l'une des parties le nie et que le bail n'a pas encore reçu d'exécution. Dans ce cas, la preuve par témoin ne marchera pas, même avec les arrhes, ça ne marchera pas. La seule preuve valide c'est le serment. Cet article nous fait savoir que si on ne veut pas de problème, on devrait mieux faire de passer le bail par écrit.

Cet article a été interprété a contrario par la jurisprudence contra legem. Elle considère que dès lors qu'il y a un début d'exécution, la preuve de l'existence du bail devient libre. Ça écarte l'article 1715 parce que la preuve du début d'exécution est elle-même libre : on peut donc prouver le début d'exécution par témoignage. En quelque sorte, la jurisprudence a désactivé l'article 1715 du Code civil.

Comment prouver le contenu du bail ?

Pour prouver le contenu, il faut appliquer les règles de droit commun du contrat du bail sauf en ce qui concerne le loyer. Pour lui, c'est **l'article 1716 du Code civil** qui s'applique. Cet article dispose que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Lorsqu'on n'a pas de bail par écrit, il y a un certain nombre de modes de preuve qui sont recevables : le premier mode c'est la quittance ; un premier loyer a été payé. Le deuxième mode c'est on demande au propriétaire d'avoir payé. Le troisième mode, c'est la possibilité pour le preneur de faire appel à un expert pour établir le prix du loyer.

Ça veut dire que le juge ne peut pas lui-même fixer le prix du loyer du contrat de bail.

Paragraphe 2 : Les effets du bail

A - Les obligations du bailleur

Les obligations du bailleur sont prévues des **articles 1719 à 1727**. Toutes les obligations du bailleur s'expliquent par celle qui est fondamentale : celle de garantir la jouissance paisible de la chose louée. Toutes les autres obligations sont accessoires de celle-là. Cette obligation est « l'âme » du contrat.

Le bailleur ne peut pas s'en exonérer ; sinon, ça n'est pas un bail.

Cette obligation n'est pas sans limite ; l'exemple le plus frappant c'est la désactivation des sonnettes électriques. Un bailleur fait installer un digicode ; un système qui nécessite de l'électricité. Un locataire demande à ce que ce digicode soit remplacé par un système mécanique. La jurisprudence retient que le bailleur n'est pas tenu que le bien loué permette l'exercice complet d'une religion donnée. Dans cet exemple, la garantie incombant au bailleur est limitée parce que ce dernier n'est pas tenu de garantir à 100% la jouissance paisible de la chose louée.

La question tient aussi aux droits et libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée ; or, on ne peut pas demander au bailleur sans demander la religion du locataire ; le bailleur n'est pas tenu de garantir l'intégralité de ce qui pourrait être considéré comme paisible par le preneur à bail.

1) Les obligations stricto sensu

Le bailleur a une obligation de sécurité. On s'attardera à l'obligation de délivrance et à l'obligation d'entretien.

- Obligation de délivrance : **L'article 1719** pose le principe de cette délivrance. Pour assurer la jouissance paisible du bien encore faut-il le délivrer. Le Code civil entend cette obligation comme celle dans le contrat de vente ; c'est l'obligation de ne pas faire, de ne pas empêcher le preneur de jouir du bien loué.

L'article 1720 nous dit que le bailleur doit délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Cette obligation n'est pas trouvée dans la vente. Dans la vente, l'objectif c'est le transfert de propriété. Dans le bail il n'y a pas de transfert de propriété, il y a un transfert d'utilisation.

Le bailleur ne peut s'attendre en retour que le preneur utilise bien la chose. Par conséquent, il faut une chose en bon état. Cet article 1720 n'est que supplétif. Les parties peuvent l'écarter et le preneur peut prendre la chose en l'état qui n'est pas forcément un bon état.

- Obligation d'entretien : Pour que la jouissance du bien soit paisible, il faut qu'elle dure tout le long du bail. Or, pour cela il faudrait que la chose soit entretenue par le bailleur.

Doit-il entretenir tout l'entretien nécessaire par la chose sachant qu'il n'a pas la chose entre les mains ? Non. C'est pourquoi le Code civil organise une répartition des réparations entre le bailleur et le preneur aux **articles 1719, 1720 et 1754**. D'un côté, les réparations locatives : le synonyme c'est menu-entretien : l'entretien quotidien qui est nécessaire par l'utilisation quotidienne du bien. D'un autre côté, les réparations importantes liées à la structure du bien : elles sont à la charge du bailleur. Les petites réparations sont à la charge du preneur, les grosses réparations sont à la charge du bailleur.

Mais les parties peuvent prévoir une autre réparation. Les clauses qui organisent de façon différente que le Code : elles sont interprétées de façon restrictive ; dans le sens des intérêts du locataire. Il y a une forme de présomption qui serait la partie « faible » dans le contrat de bail.

2) Les garanties

Le bailleur a aussi des garanties. On les retrouve comme en matière de vente : les vices cachés.

- Garantie des vices cachés : C'est l'article 1721 qui pose cette garantie comme pour la vente à quelques nuances :

- L'action en garantie des vices cachés n'est pas enfermée dans le délai de deux ans ;
- La garantie s'étend aux vices apparus en cours de bail ;
- Les clauses limitatives sont valables (droit commun). En matière de bail d'habitation, on ne peut pas stipuler des clauses limitatives (droit spécial).

- Garantie d'éviction : Le bailleur doit garantir le preneur contre son fait personnel, le fait personnel du bailleur.

- **Sur le bail commercial** : Quand on a un bailleur qui loue un fonds de commerce, peut-il s'installer non loin du local qu'il loue et ouvrir un commerce pour son propre compte ? Serait-ce une obligation de non-concurrence ? La garantie contre l'éviction n'impliquait pas une non-concurrence selon la jurisprudence. En revanche, il y a quasiment tout le temps une clause de non-concurrence.

- **Sur le fait des tiers** : Ça dépend de l'éviction :

-> Est-ce un trouble de droit ?

- **Sur le trouble de droit du fait des tiers** : Oui. Si le tiers débarque avec un titre juridique ; le bailleur doit garantir la protection contre l'éviction du preneur par le tiers. En général, on préfère celui qui est entré en premier en possession de la chose. On fait jouer la garantie contre l'éviction parce que le bailleur doit garantir le preneur contre le trouble de droit des tiers.

-> Est-ce un trouble de fait ?

- **Sur le trouble de fait du fait des tiers** : Non, car l'article 1725 dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Cet article est supplétif. Mais il faut aussi s'entendre sur la notion de tiers : il faut que ce soit un tiers à l'égard du bailleur. Par exemple :

- Un bailleur qui est propriétaire d'un appartement dans une copropriété. Doit-il garantir le fait d'un autre copropriétaire ? Non, on ne peut pas lui demander de protéger le preneur contre le tiers parce qu'il est un « vrai » tiers, il n'a aucun lien avec le propriétaire ;

- Mais si la personne est un autre locataire d'un autre appartement, le bailleur doit alors la garantie contre les troubles de fait parce que l'autre locataire n'est pas un véritable tiers.

B - Le statut du preneur

Le preneur a des obligations mais aussi des droits.

1) Les obligations du preneur

Ces obligations sont prévues des [articles 1728 à 1735](#). La première obligation c'est l'usage de la chose louée ; évidemment c'est un droit. En réalité c'est aussi une obligation parce qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec la chose. Il doit en faire l'usage « d'un bon père de famille ». Il doit utiliser la chose sans excès. C'est une notion à contenu variable appréciée in concreto.

On peut alors mettre des clauses liées à l'usage. C'est fréquent et la question est de savoir jusqu'où on peut aller. Dans les contrats de baux, on trouve une clause d'habitation bourgeoise ; dans le local loué, il faut y habiter, pas d'y faire un commerce ou une activité libérale.

Dans un contrat d'habitation, peut-on mettre y mettre clause d'habitation personnelle ?

C'est la clause qui interdit d'inviter des amis ou des proches. Cette clause a été condamnée par la jurisprudence sur la base du droit au respect de la vie privée issu de la CEDH.

- **Sur la restitution de la chose** : Sur le preneur, pèse l'obligation de restituer la chose en temps voulu. Elle est prévue par [l'article 1730](#). Sans cette obligation, ce n'est pas un contrat de bail.

Simplement, cette obligation pose plein de problèmes pratique ; on doit restituer la chose qui a été louée. La dérivée de cette obligation c'est l'obligation de conservation qui pèse sur le locataire (ce sont les réparations locatives). Le preneur va avoir un usage qui va user la chose mais il faudra qu'à la fin, il ait conservé la chose pour la rendre telle qu'elle lui a été délivrée (1754). Le preneur a l'obligation d'interdiction de modifier la substance de la chose.

- **Sur les états des lieux** : Il faut un état des lieux avant le début du contrat de bail et à la fin du contrat.

S'il n'y a pas d'état des lieux, il y a une présomption : le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état de réparation locative.

Sur un bien dégradé en fin de bail : le preneur répond de la dégradation, c'est le principe posé des [articles 1732 à 1735](#).

Il peut quand même s'exonérer en démontrant l'absence de faute. Il peut démontrer l'absence de préjudice pour le bailleur. Par exemple, sur les trous dans les murs, le locataire répond de cette dégradation en bouchant le trou. Si le contrat de bail se termine parce que le propriétaire met fin au contrat pour détruire le bien et le reconstruire, il ne subit donc pas de préjudice. En matière d'incendie, la règle spéciale prévue aux [articles 1733 et 1734](#), elle prévoit trois cas d'exonération. Ce régime s'explique par une difficulté probatoire ; il y a une présomption qui pèse sur celui qui utilise la chose.

- **Sur le paiement du loyer** : L'obligation de payer le loyer. Il n'empêche que cette obligation pose quelques problèmes : le bailleur cherche à se prémunir contre les impayés ; il demande alors un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie est valable par principe, c'est normal que le créancier cherche à avoir des garanties de paiement. Mais pour les baux d'habitation et commerciaux, il y a des conditions à respecter.

A quoi sert le dépôt de garantie ? Paiement des loyers ou bonne restitution du bien ?

Si la garantie est une garantie de restitution, le bailleur ne peut pas s'en prémunir comme une garantie de loyer impayé et inversement si le preneur veut invoquer le même moyen.

- **La caution** : Le bailleur demande au locataire de faire venir une autre personne qui va s'engager subsidiairement à payer le loyer si le locataire ne le paye pas. La caution est un contrat de sûreté.

CM8 : 4/03

2) Les pouvoirs du preneur

Ils se repèrent quand il y a un changement de preneur. Deux hypothèses [article 1717 du CC](#) :

- Cession de bail : elle est permise par le Code civil. En revanche, dans la quasi totalité des baux spéciaux, la cession de bail n'est en principe pas permise. Il y a donc une cession du contrat : le preneur cède sa place, sa position contractuelle. Normalement on ne devrait pas appliquer l'article 1690 du Code civil, qui s'applique qu'aux cessions de créances. Mais la JP a décidé d'appliquer quand même l'article 1690 à la cession de bail, pour des questions d'opposabilité. Par exemple il faut régler la question de l'opposabilité au bailleur, etc, qui est réglé par l'article 1690 du CC.

- Sous location : prévu aussi par 1717 du CC. Idem, le CC autorise aussi la sous location dans un bail de droit commun. Mais dès qu'on est dans un bail spécial (habitation, professionnelle, etc) elle est interdite par principe, est autorisée de façon exceptionnelle. Dans la sous location, il y a un contrat qui lie le preneur avec un sous preneur. On se demande alors si le sous-locataire a un rapport direct avec le bailleur ? Non, seule relation directe avec le preneur. En principe, le bailleur ne peut pas attaquer le sous-locataire, et inversement. Deux exceptions : article 1753 d CC :

- **si le loyer n'est pas payé** : le bailleur peut agir contre le sous-locataire en lui demandant de payer le sous-loyer, dans la limite du loyer. On peut pas le forcer à payer un loyer pour lequel il ne s'était pas engagé.
- exception que l'on trouve dans le droit commercial, quand il y a une sous-location, le sous-locataire a un **droit direct au renouvellement contre le bailleur** : le droit au renouvellement qui profite au preneur doit aussi profiter au sous-locataire.

=> Dans les régimes spéciaux il y a un principe directeur qui est de garantir au preneur une stabilité. Ce principe n'existe pas dans les baux de droit commun.

Section 2 : Les régimes spéciaux

En pratique, le bail commun est très peu utilisé parce que la plupart des régimes qui sont utilisés sont des baux spéciaux. Le code civil évoquait déjà la possibilité de contrats de location spéciaux, en évoquant notamment les baux ruraux.

Paragraphe 1 : Le bail d'habitation

Il y a un régime spécial car on parle de politique du logement. La grande majorité des citoyens se logent grâce à un bail. Pour le législateur c'est une vraie difficulté car doit trouver un équilibre entre les intérêts des preneurs et les intérêts du bailleur.

C'est pourquoi la loi française a beaucoup bougé, et est très marquée par la couleur politique des législateurs. Parfois elle penche + du côté du locataire et parfois + du côté du propriétaire.

- Loi de 1948 : visait les habitations en ville où il y avait une pénurie de logement en raison de la SGM. Cette loi donne un certain nombre de droits au locataire, avec notamment une fixation du loyer : le loyer n'est pas censé augmenter, et un droit au maintien dans les lieux très forts. Mais : loyer qui augmente pas, proprio qui peut pas faire des travaux et locataire qui s'en vante, conduit à la destruction de bcp d'immeubles.

- Plusieurs Lois à partir de 1981 : les droits des locataires se sont épaissis, contrôle de loyer, droit au renouvellement et droit de préemption (si le proprio vend il doit d'abord proposer au locataire en place).

- Les lois suivantes ont essayé de libéraliser la fixation des prix, permettre l'augmentation des loyers, etc et d'autres lois sont venues pour limiter les indemnités en cas de renouvellement.

- la loi du 6 juillet 1989 est tjr en vigueur (mais bcp modifiée) impose bcp de formalisme, qui sont souvent contre le bailleur. Il y a aussi des clauses obligatoires : il y a des points clefs dans les contrats de bail que le contrat doit prévoir : durée, date d'entrée et de sortie, désignation des locaux, états des lieux entrée et sortie, etc.

- Loi sur la qualité du logement : dispositif qui permet de garantir une certaine qualité du logement (taille, sanitaire, qualité énergétique etc).

Paragraphe 2 : Le bail commercial

Question politique importante car permet aux commerçants de faire leur commerce, d'attirer leur clientèle. Il y a donc des droits qui protègent le locataire, comme un droit au renouvellement, (indemnité d'éviction si le proprio veut mettre le commerçant dehors), augmentation des loyers plafonné.

Paragraphe 3 : Le bail professionnel

Permet au professionnel d'avoir un lieu pour exercer sa profession. Là aussi il y a des règles qui encadrent la sécurité du professionnel. Le lieux est très important et le législateur répond a cela : **loi de 1986** offre un certain nombre de garanties au locataire (durée minimale de 6 ans), droit au renouvellement plus faible car pas d'indemnité d'éviction. C'est pour ça que certains professionnel préfèrent passer un contrat commercial pour être mieux protégé.

Paragraphe 4 : Les baux ruraux

Traités dans le code rural et de la pêche maritime et sont des contrats spécifiques mais qui obéissent a la même logique de stabilité. Durée minimale de 9 ans, droit de renouvellement voir bail a perpétuité, droit de préemption, droit de transmission (transmet aux héritiers qui participe a l'exploitation agricole).

Les baux ruraux peuvent porter sur des exploitations agricoles toutes entières (fermes, animaux, tracteurs etc) ou divisé (juste sur les animaux, juste sur les terrains, etc).

=> C'est le bail le plus protecteur pour le locataire

Chapitre 2 : Les contrats de prêts

Il y en a 2 sortes parce que deux catégories de choses : les choses qui quand elles sont utilisées elles se détruisent (choses consommables) et celles qu'on peut utiliser sans les détruire.

En 1804, dans **l'article 1874** ils ont décrit les 2 sortes de contrats de prêts :

- **prêt à l'usage** pour les choses qui se détruisent pas

- **prêt de consommation** pour les choses consommables ≠ du prêt à la consommation

=> Ces deux catégories se ressemblent avec une définition commune : Contrat en vertu duquel le prêteur remet une chose a l'emprunteur pour que celui ci s'en serve a charge de restitution.

Mais on a du mal a différencier le bail avec le contrat de prêt. Distinction :

- le contrat de prêt est vu par la doctrine comme étant un contrat unilatéral : car contrat réel.

- le contrat de bail est un contrat personnel, avec des obligations réciproques.

Dans le contrat de prêt la remise d'une chose est un acte, tant qu'il n'y a pas de remise de la chose il n'y a pas de prêt = il n'y a donc pas d'obligation de prêt. Par principe, le contrat de prêt est un contrat d'ami, il n'y a pas de prix (alors que dans le contrat de bail oui), c'est donc un contrat gratuit (ce n'est pas un contrat a titre onéreux), toutefois il existe des contrats de prêts avec un prix.

Ce n'est normalement qu'après la remise de la chose que l'obligation naît, et n'est que sur la tête de l'emprunteur. Mais, il y a quand même quelques obligations qui peuvent peser sur le prêteur.

Section 1 : Le prêt à l'usage (commodat)

Le prêt à l'usage peut porter sur tous les biens du moment qui ne sont pas consommables. C'est un contrat qui est par principe gratuit, sauf qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours mais aussi dans la vie des affaires. Mais ça n'est pas pour autant un contrat onéreux car il n'y a pas de prix.

Prêts intéressés : pas payant directement, mais un peu onéreux. Au supermarché on va prendre un chariot, que l'on nous prête. Mais ce prêt là n'est pas un service d'ami, c'est seulement l'intérêt du supermarché.

La JP peut donc justifier un changement de régime.

Contrat d'ami : le prêteur rend service à l'emprunteur : on est + sévère avec celui qui profite de la situation, soit l'emprunteur.

Si le prêt est intéressé, on va être plus sévère avec le prêteur car il profite du fait de prêter des choses. On va lui imposer de prêter une chose convenable etc.

-> lorsque le garagiste prête une voiture, c'est un prêt intéressé, il va attirer le client.

Paragraphe 1 : les obligations qui naissent du prêt à l'usage

A - Obligation de l'emprunteur

Prévu aux **art 1880 et suiv du CC**.

- Obligation sur l'usage : l'emprunteur doit respecter l'usage de la chose prévue conventionnellement. Il est soumis à des limites d'utilisation. Ces limites peuvent être expresses, implicites, etc.

L'usage est censé être personnel, il y a une forme d'intuitu personae. Si l'emprunteur ne respecte pas les limites d'utilisation : la chose va devenir à ses risques, il va y avoir un transfert des risques : il va devoir assumer la perte de la chose. Aussi, la chose prêtée n'est pas censée être utilisée à des fins lucratives commerciales.

- Obligation sur la restitution : il n'y a pas de transfert de propriété, l'emprunteur doit rendre la chose. C'est une obligation essentielle du contrat. La restitution se fait *in specie* = on rend en nature, on rend la chose même qui est prêtée. C'est donc une obligation de résultat. Toutefois, dans certains cas cette obligation de restitution en nature pose des problèmes, surtout quand c'est un prêt intéressé. **Affaires des cuves** : pompiste qui stocke du pétrole, prêt de cuves de la compagnie pétrolière, à condition qu'il achète chez lui. Il veut plus tard changer de compagnie, mais la compagnie pétrolière lui impose une restitution en nature des cuves (enterrées etc ...). La cour refuse qu'il rende en nature, car c'est un prêt intéressé ce sera alors une restitution en argent. = si la restitution est très chère, inutile, contraire aux intérêts du marché, on peut passer à une restitution en valeur et plus *in specie*.

La question des dépenses d'entretien : l'emprunteur est censé restituer la chose telle qu'il l'a reçue. Il a le droit de l'utiliser, certes, mais il va devoir l'entretenir, la conserver. Cela lui empêche, en principe de réclamer des remboursements d'entretien au prêteur. (les dépenses extraordinaires liées à un problème de structure de la chose sont susceptibles d'être remboursées).

Toute dégradation de la chose est présumée être de la responsabilité de l'emprunteur = présomption simple, l'emprunteur peut prouver que c'est pas sa faute.

B - Obligation du prêteur

Dans le contrat de prêt, le prêteur remet la chose puis il n'est plus censé avoir d'obligations. Mais **articles 1888 à 1891 du CC** parlent des engagements de ceux qui prêtent à l'usage. Ces obligations sont éventuelles, exceptionnelles.

- **L'article 1890** met sur la tête du prêteur la responsabilité de **rembourser les dépenses extraordinaires** réalisées sur la chose par l'emprunteur.

- **L'article 1891 du CC** dit que le prêteur est responsable s'il connaissait les défauts et qu'il n'en a pas averti l'emprunteur. = il est **responsable** que des **vices apparents**, sauf quand c'est un prêt à intérêt = on va mettre aussi sur sa tête la garantie des vices cachés.

Paragraphe 2 : La durée du prêt à l'usage

C'est une obligation temporaire. **L'article 1888 du CC** dit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu.

Soit durée interne prévue au contrat, soit pas de durée prévue et donc la limite sera l'utilité de la chose « le contrat prend fin après que la chose est servie à l'usage pour lequel elle a été empruntée ».

Mais alors si on prête un local d'habitation ? L'usage de la chose dure toujours... il faut préciser la durée du prêt. Cela veut dire que lorsqu'on prête quelque chose d'important il vaut mieux faire un contrat et préciser la durée...

L'article 1889 du CC peut donner un moyen d'interrompre le prêt : « —. » il faut prouver un besoin pressant..

L'article 1888 du CC dit que la chose a dû servir à l'usage pour laquelle elle a été empruntée : si on l'applique à la lettre on risque d'aller au contraire du prêteur, comme pour la location. -> Situations injustes

La JP a commencé à atténuer la lecture de l'article. => **Décision en 2004** où la cour a décidé que lorsque aucun terme est prévu, sans que terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (souvent 6 mois pour les logements).

Section 2 : Le prêt de consommation

S'applique à des biens consommables. Parmi ces biens il y a l'argent, la nourriture, etc.

L'argent est un prêt de consommation mais spécifique.

Paragraphe 1 : Le droit commun du prêt de consommation

Le prêt de conso est désigné par son appellation latine « *mutuum* » = emprunter.

Ce prêt porte sur des choses consommables qui peuvent l'être par nature ou qui peuvent l'être par autorisation du prêteur. C'est un prêt original car les choses prêtées vont être détruites par leur usage. Malgré tout il y a une obligation de restitution. Le contrat de prêt de consommation est un contrat qui entraîne le transfert de propriété. Les risques de la chose vont reposer sur l'emprunteur.

Il y aura donc une restitution en valeur, une chose équivalente.

Ce contrat est en principe gratuit mais peut aussi être onéreux, il peut entrer dans le cadre d'une opération d'affaire et va devenir un prêt à intérêt. Mais change pas grand chose car de toute façon la chose est au risque de l'emprunteur.

Ex : prêt d'un paquet de gâteau : on peut soit restituer un autre paquet de gâteau, soit restituer une somme d'argent qui va permettre au prêteur de racheter un autre paquet.

Paragraphe 2 : Le prêt d'argent

C'est une sous-catégorie du prêt de consommation, mais porte sur l'argent, car c'est la chose la plus consommable qui soit. On peut prêter de l'argent, l'emprunteur va l'utiliser, il ne pourra plus le rendre, il va devoir restituer la même somme.

Toutefois le prêt d'argent est un contrat très largement utilisé : contrat essentiel de la vie en société. Contrat qui peut rester un contrat d'ami car l'est pas principe, mais la plus part du temps il est utilisé comme un vrai contrat onéreux.

On va prêter de l'argent contre un prix, avec des intérêts.

Son régime juridique est sorti du Code civil

CM9 : 11/03

A - La formation

- Conditions de fond :

- Le prêteur : si c'est un **prêteur désintéressé** il ne demandera pas d'intérêt, ça peut être n'importe qui (personne morale ou physique). Si c'est un **prêteur intéressé** il va exiger le paiement d'intérêt, ça devient un contrat onéreux. Ça ne pourra pas être n'importe qui : le prêt d'intérêt a titre onéreux est un titre de banque (que les banques qui peuvent le faire). => on considère qu'une personne normale peut faire une seule fois un prêt à intérêt. Au delà ça devient une habitude et donc interdit.

- L'emprunteur : il est présumé comme étant la partie faible, il est donc protégé. Dans le code de la consommation il y a bcp de règles qui protègent le consentement avec une offre préalable auquel l'emprunteur doit répondre après un délais précis (minimum 15 jours parfois).

- Le prix : pas obligatoire car en principe le contrat de prêt d'argent est un contrat d'ami mais l'exception prend bcp de place et il y a très fréquemment des prêts payants. Ce prix s'exprime par un taux d'intérêt qui va s'appliquer au capital prêt. Les intérêts représentent le prix du service rendu. Ce taux se fixe : le principe est que le prix est fixé par la libre fixation des parties. Mais il y a toutefois un plafond : le taux de l'usure = le taux d'intérêt est tellement élevé que l'emprunteur n'arrivera jamais à tout rembourser. Dans ce cas on considère que le taux est excessif et est donc interdit. Mais comment le sanctionner ? On ne peut pas annuler le prêt. Ainsi, ce qu'on va annuler ce n'est pas le prêt mais uniquement le taux d'intérêt.

-> **Question de l'anatocisme** : taux d'intérêt qu'on applique sur un capital, il est en fonction calculé en fonction du temps (10% à l'année ou par mois par ex). Si on fixe une période de 1 an, on va calculer la somme qu'il reste à payer et on va appliquer le taux d'intérêt (1000€ à rembourser + 10% = 1100€). Si on prolonge sur plusieurs années mais on doit 10€ par mois : capital à force de remboursement diminue mais quand même des intérêts qui s'applique. Mais alors l'intérêt s'applique t'il uniquement sur le capital ou sur les intérêts dû ? Si c'est que sur le capital l'assiette est raisonnable, mais si sur capital + intérêt dû ça fait bcp plus cher.

L'anatocisme est la capacité du prêteur de réclamer le taux d'intérêts sur le capital mais aussi sur les intérêts dû
= La possibilité d'anatocisme est limitée à une année entière. (c'est la capitalisation des intérêts)

- Conditions de forme :

- Stipulation des taux d'intérêts : dans certains contrats de prêt il y a un taux d'intérêt légal (la loi qui s'applique), en revanche on peut aussi ne pas appliquer le taux d'intérêt légal : taux d'intérêt conventionnel. Ce taux d'intérêt conventionnel ne peut être valable qu'il est **express** et **écrit**. S'il ne respecte pas ces 2 conditions le taux sera nul. Ces conditions sont très contrôlées en JP.

-> **Mention obligatoire** : Il faut, en plus du taux d'intérêt la mention obligatoire du TAEG : taux annuel d'effectif global. Pour éviter les dolus malus (taxes, assurances, frais d'ouverture de dossier etc qui pourraient tromper l'emprunteur).

- Formalité probatoire : normalement le contrat est un contrat réel et unilatéral. Il faut maintenant prouver l'obligation de remboursement qui pèse sur l'emprunteur : **article 1326 du CC**. Pour prouver un contrat de prêt il faut prouver la remise des fonds + l'engagement de restitution + engagement de remboursement

B - Effets du contrat

- Effets pour l'emprunteur : il faut qu'il rembourse le capital -> le problème avec le remboursement d'une somme d'argent c'est un problème de valeur. Le problème qui se pose c'est l'inflation
-> Remboursement en valeur : on rembourse la valeur qui a été prêtée, on tient compte de l'inflation etc
-> Remboursement nominaliste : le droit français a choisi cette forme de remboursement : on rembourse la somme exacte qui est écrite.

Ainsi, le taux d'intérêt est là pour compenser les variations d'argent qu'il y a avec le temps.

Question du **remboursement anticipé** : est-ce qu'on peut rembourser le contrat plus vite que prévu ? Si le contrat est un prêt d'argent payant, le prêteur se paie avec l'effet du temps, + c'est long mieux c'est pour lui.

Est-ce que l'emprunteur peut forcer l'emprunteur à payer plus tôt ? Non. On ne peut pas, sans l'accord du prêteur anticiper le remboursement.

Question de la **déchéance du terme** : sanction lorsque quelqu'un bénéficie d'un avantage et s'en voit privé parce qu'il ne le mérite plus. Dans le prêt l'emprunteur bénéficie de temps pour rembourser, c'est un avantage. Mais s'il perd la confiance du prêteur (ne paye plus) : on va pouvoir trouver des clauses de déchéance du terme, l'emprunteur devra immédiatement rembourser TOUT le capital.

- Effets du prêteur : le prêteur ne devrait pas avoir d'obligation car c'est un contrat unilatéral, il a remis les fonds et on lui demande juste d'attendre. Toutefois, la JP a accru différentes obligations qui vont peser sur le prêteur et modifier l'image du prêteur.

Aujourd'hui le contrat de prêt d'argent payant n'est plus vrm un contrat unilatéral mais un contrat synallagmatique car il y a des obligations qui pèsent sur le prêteur.

- **Obligation de prudence** : vise le moment où l'établissement de crédit accorde le prêt. Il doit mettre en garde l'emprunteur sur les risques d'un prêt d'argent, il doit lui expliquer comment ça marche, que l'argent prêté devra être remboursé etc. Si le prêteur voit que l'emprunteur n'a pas la capacité de rembourser il doit refuser le prêt. S'il ne le fait pas il sera en faute.

- **autres formes d'obligations** : assurance qui couvrira l'impossibilité de rembourser le prêt en raison d'une maladie, chômage, etc. -> obligation de conseil

Titre III - Les contrats relatifs aux services

Les contrats qui portent sur des services ont en commun un type d'obligation : l'obligation de faire. Cette obligation est une catégorie juridique mais extrêmement large. Cette façon d'englober un peu tout et n'importe quoi pose au juriste des problèmes de qualification. C'est difficile de classer ces contrats de service. 3 contrats spécifiques du code civil :

- contrat d'entreprise
- contrat de mandat
- contrat de dépôt

Difficile de les classer et donc parfois on va appliquer le droit commun.

Chapitre 1 : Contrat d'entreprise

Contrat défini par l'article 1708 du CC qui le nomme en disant que c'est un louage d'ouvrage et d'industrie. On parle maintenant que de contrat d'entreprise. C'est considéré comme la catégorie fourre-tout car elle englobe bcp de choses. C'est une qualification qui a fait l'objet de glissement sémantique : on l'appelle le contrat de prestation de service. Sauf que c'est une notion + économique que juridique.

Cet article définit le contrat d'entreprise comme : contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige envers le maître de l'ouvrage à exécuter un travail contre rémunération mais de manière indépendante et sans représentation. => Définit le contrat de façon positive + négative.

C'est donc un contrat onéreux synallagmatique et innommé. Il porte sur un travail mais ce n'est pas le contrat de travail car indépendance. Il n'y a pas de lien de subordination car travail réalisé en toute indépendance.

Ce travail indépendant peut être de toute nature : manuel, physique, intellectuel, etc.

Le code civil parle de ce travail, de ce qu'on peut faire etc mais très 19e siècle.

Ce contrat est traité par le Code Civil mais n'a pas échappé au mouvement d'hyperspécialisation. Il n'y a donc pas que le CC pour en traiter, il y a aussi le code de la consommation, etc.

Enfin, la JP traite aussi bcp de ces contrats.

Contrats d'entreprise ≠ certains contrats de vente -> on dirait que c'est très différent mais en fait il y a parfois des formules qui sont très proches.

- Dans le contrat d'entreprise la **détermination du prix** n'est pas une condition de formation du contrat, alors que dans la vente oui.
- Dans la vente le **transfert de propriété** se fait lorsqu'il y a accord sur chose et prix, dans le contrat d'entreprise le transfert se fait au jour de la livraison.
- Dans le contrat de vente le vendeur a des **garanties légales** de paiement (privilèges du vendeur), alors que l'entrepreneur n'a pas les mêmes garanties
- **clauses de responsabilité** : les parties sont libres d'alléger, exclure carrément la resp de l'entrepreneur
- **chaîne de contrat** : possibilité d'agir d'un bout à l'autre de la chaîne. Par principe le contrat d'entreprise n'est pas un contrat translatif de propriété.

Mais c'est pas toujours facile de faire la différence entre les 2. Notamment lorsque l'obligation de faire est fabriquer une chose dont la propriété sera transférée au maître de l'ouvrage.

Article 1787 et 1711 du Code civil : donnent des indications pour réfléchir :

-> Qui fournit les matériaux qui permettent de fabriquer la chose : si fourni par le client c'est à l'évidence un contrat d'entreprise. Mais si les matériaux ne sont pas fournis par le client ?

-> lorsqu'il n'y a pas de travail spécifique de l'entrepreneur (il va prendre des fournitures et faire quelque chose lambda) c'est une vente. En revanche lorsque la prestation qu'on attend de lui est une chose adaptée au client c'est un contrat d'entreprise.

Le code de la consommation assimile au contrat de vente les contrats de fourniture de meuble à fabriquer ou à produire.

Le contrat d'entreprise ≠ le contrat de bail

Obligation de faire alors que n'existe pas dans le contrat de bail.

Si on sait pas : c'est l'accessoire qui est utilisé. Dans le contrat d'hôtellerie ce qui est prédominant c'est pas la mise à disposition de la chambre mais tous les services qui sont à côté donc contrat d'entreprise.

On peut aussi faire une qualification distributive : un peu des 2.

Le contrat d'entreprise ≠ le contrat de travail

Si on dit que c'est un contrat de travail, la rémunération est un salaire donc charge salariale + charge patronales + cotisations etc qui vont alourdir la facture.

Le contrat d'entreprise nécessite qu'il n'y ait pas de représentation.

Cela permet de distinguer le contrat d'entreprise ≠ contrat de mandat :

- Formation du contrat :

C'est le droit commun qui est applicable. C'est un contrat consensuel il n'y a pas de forme précise. Mais il y a des pratiques qui se sont installées, comme le devis, qui peut être payant, afin d'établir le prix de la prestation.

CM10 : 18/03

- Effets du contrat :

Le principe est que le maître de l'ouvrage acquiert la propriété du bien qui a été produit, réparé etc. Ce qui signifie que le maître de l'ouvrage, en devenant proprio il a toutes les actions du proprio.

Mais comment devient-il proprio ? Différence fondamentale avec le contrat de vente car le contrat d'entreprise n'est pas un contrat translatif. Le transfert de proprio dans le cadre d'un contrat d'entreprise est qu'un accessoire c'est pas l'objet principal. = c'est un contrat acquisitif de propriété, il entraîne l'acquisition.

Le mécanisme de transfert de propriété est un transfert en soit, mais la c'est pas lui qui est utilisé. En matière mobilière il devient proprio par accessoire, **théorie de l'accessoire**.

En matière immobilière c'est le **mécanisme de l'accession**.

Si on est proprio d'un terrain on a un droit d'accession : tout ce qui vient sur le terrain comme un accessoire devient notre propriété. Par exemple, un arbre qui pousse sur notre terrain, on en devient propriétaire.

Ex du contrat d'entreprise : le maître d'œuvre construit une maison sur notre terrain, par le mécanisme de l'accession la maison devient à nous.

Section 1 : Les obligations de l'entrepreneur

L'obligation qui pèse sur lui est celle de réaliser la chose promise. Il peut la réaliser lui-même, soit la faire réaliser par un tiers.

Paragraphe 1 : Réalisation la prestation

A - L'entrepreneur réalise la prestation

Il va falloir déterminer le contenu exact de la prestation, à quoi il s'est engagé. Cela va dépendre du contrat. Si on est pas précis on va pas pouvoir évaluer l'exécution de la prestation de l'entrepreneur.

-> Comment traiter la question de l'inexécution de l'obligation ?

On va pouvoir forcer l'entrepreneur à réaliser la chose qu'il a promis, on applique l'article 1221 du CC. Toutefois, lorsque l'exécution en nature est impossible ou qu'il y a une disproportion manifeste entre le coût qui pèse sur le débiteur et l'intérêt du concerné on estime qu'il n'y aura pas d'exécution forcée.

Cette exécution forcée peut être assortie d'une astreinte (somme d'argent à laquelle va être condamné le débiteur pour chaque jour de retard).

lorsqu'il y a une prestation qui est directement rattachée aux qualités personnelles de l'entrepreneur, l'astreinte sera pas possible. Par ex, si on commande un portrait à un peintre on pourra pas lui imposer une astreinte.

De plus, quand le créancier sent que ça va être difficile, il a des mesures qui contournent la résistance du débiteur. Le créancier a la possibilité de demander au juge de faire réaliser la prestation par quelqu'un d'autre mais aux frais du débiteur. => Possibilité de remplacement.

-> Le créancier (maître d'œuvre) a aussi la possibilité de faire refaire une prestation mal faite.

-> Comment mesurer l'intensité ? Lorsque le contrat indique juste l'obligation sans indiquer l'intensité, c'est le juge qui va le faire. Il va chercher des indices si obligation de résultat ou de moyens par ex.

Déjà question de savoir si prestation intellectuelle ou matérielle. En principe :

- Intellectuelle = moyen. Les avocats, médecins etc il pèse sur eux une obligation de moyens.

- matérielle = résultat. Mais il faudra mettre en avant d'autres indices. Question de savoir si l'entrepreneur a fourni la matière ou pas. S'il a fourni la matière il va répondre que de sa faute = pèse sur lui une obligation de résultat atténuée. Cela veut dire que s'il arrive pas à démontrer qu'il a pas commis de faute, il sera responsable.

De plus, ce qui prime, ça reste le contrat. Si le contrat indique l'intensité de l'obligation, le juge devra le suivre.

-> Sur qui pèse la perte de la chose (qui serait pas la cause d'une des parties mais d'un cas de force majeure par ex) ?

Question réglée par articles 1788 et 1790 du CC. Mais il faut encore souligner que les parties peuvent toutefois organiser un régime des risques spécifique à elles.

Les articles distinguent 2 hypothèses : lorsque l'entrepreneur fournit la matière et lorsqu'il l'a fournie pas.

- entrepreneur fournit la matière : Si le contrat est silencieux, les risques vont peser sur l'entrepreneur jusqu'à la réception de l'ouvrage. À partir du moment où l'ouvrage est réceptionné par le maître d'ouvrage, le risque passe sur la tête du client.

- fournit pas : la règle est la même, c'est l'entrepreneur qui assume la perte de l'ouvrage. Sauf si la perte est due à un vice de la matière c'est celui qui a fourni la matière (maître de l'ouvrage).

B - L'entrepreneur fait exécuter la prestation

- Co-traitance : il y a pour un même ouvrage plusieurs entrepreneurs qui interviennent, chacun chargé par le maître de l'ouvrage (ex : le plombier, le peintre, l'électricien etc). Pour faciliter les relations avec le maître de l'ouvrage on peut désigner un chef de file.

- Sous-traitance : le maître d'œuvre a son entrepreneur qui va ensuite embaucher des sous-traitants pour l'aider. Par exemple on embauche un entrepreneur général pour construire une maison qui va lui ensuite embaucher l'électricien, la plomberie, etc. Dans cette hypothèse le maître de l'ouvrage est en relation qu'avec l'entrepreneur principal. Mais cela pose des problèmes parce que les sous-traitants peuvent faire n'importe quoi etc.

Loi du 31 dec 1975 : la sous traitance est réglementée. A pour obj de protéger le sous-traitant contre les défauts de paiement, éviter les faillites en chaîne et protéger le maître de l'ouvrage.

=> On ne peut pas écarter les dispositions protectrices de cette loi. Cette loi prévoit des dispositifs qui permettent aux sous traitants d'agir contre le maître de l'usage pour se faire payer, le maître de l'ouvrage peut agir contre l'entrepreneur, etc.

1) Action directe du sous traitant

Le sous-traitant peut demander directement un paiement au maître de l'ouvrage. Cette action directe est imparfaite car subsidiaire : il faut d'abord que le sous traitant ait adressé une lettre de mise en demeure.

Le maître de l'ouvrage mérite d'être averti d'une problématique donc il faut mettre en copie de la mise en demeure le maître de l'ouvrage.

Il y a aussi des limites : le sous traitant va demander un paiement au maître de l'ouvrage, normal car c'est lui qui va profiter du travail. Mais il faut penser à la situation dans laquelle le maître de l'ouvrage a déjà tout payé. (l'entrepreneur principal a pris l'argent et pas payé les sous traitants). Le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'à hauteur de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal : il va pas payer +.

Aussi, quand on va demander au maître de l'ouvrage de payer, ce dernier a le droit de se défendre. Il va pouvoir faire valoir des exceptions contre l'entrepreneur principal. => **exception d'inexécution**, le maître d'ouvrage va dire à l'entrepreneur principal qu'il a pas exécuté son obligation.

Enfin, l'action directe est possible que si le sous-traitant était connu du maître de l'ouvrage, voir même excepté par ce dernier.

2) La responsabilité délictuelle du sous traitant

Question qui s'est longtemps posée de savoir quelle relation lie le sous traitant et le maître de l'ouvrage. Est-ce une responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle ?

Les différentes chambres de la cour de cassation se sont longtemps opposées sur cette question.

Arrêt 1991, « Besse » : l'action entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage est une action délictuelle.

On a des obligations accessoires forcées : obligation de conseil, d'information, etc.

L'entrepreneur doit aussi assurer la sécurité au maître de l'ouvrage

Section 2 : Les obligations du maître de l'ouvrage

Paragraphe 1 : Payer le prix

- Détermination du prix :

- On peut faire une **détermination conventionnelle**, par le consentement des parties. Les parties peuvent se mettre d'accord avant la réalisation, pendant ou après la remise de la prestation.

- Les parties sont parfois pas d'accord : **détermination judiciaire**. Le juge peut intervenir pour déterminer le prix a posteriori car le prix est pas une condition de formation. Il va tenir compte de l'importance du service rendu, la qualité du travail, peut faire appel à un expert, etc. Il va trancher le désaccord entre les parties.

- Paiement du prix : normalement le paiement du prix est fait à la fin des travaux. Mais en réalité ça change.

Par exemple, au cinéma on paye au début, alors qu'au resto on paye à la fin. Aussi, on peut payer plusieurs fois (au début, pendant les travaux et a la fin) etc.

L'entrepreneur, pour se faire payer son prix, il a une garantie : le droit de rétention (que sur des biens meubles). Si on paie pas il donne pas la chose.

- Réfaction du prix : le juge est pas censé intervenir sur le prix dans un contrat. Mais les contrats d'entreprises sont l'exception. On peut faire intervenir le juge alors même que le prix est fixé s'il ne convient pas a une des parties = c'est la réfaction / révision du prix. Le juge va intervenir à la fin de la prestation. Le juge perd cette possibilité de réviser lorsque les parties qui fixent le prix se sont entendues sur le prix alors même que la prestation été réalisée.

Paragraphe 2 : Prendre livraison

Le maitre de l'ouvrage doit prendre livraison, c'est a lui de retirer la chose. Les parties peuvent toutefois prévoir différemment (la chose sera livrée au domicile du maitre de l'ouvrage par ex).

S'il ne va pas retirer la chose, l'entrepreneur aura la possibilité au bout d'un an de se faire autoriser par le juge pour se débarrasser de la chose (sauf si prévu dans le contrat).

Paragraphe 3 : Prendre réception

Receptionner la chose ce n'est pas aller la récupérer : receptionner c'est un acte juridique unilatéral. Le maitre de l'ouvrage approuve la prestation. La reception juridique de la chose va entrainer des conséquences : transfert des risques, obligation de payer. L'aprobation va couvrir tous les défauts apparent, s'il approuve il pourra plus se plaindre des défauts visibles. Il a donc la posisbilité d'emettre des réserves si l'ouvrage ne correspond pas à la chose promise. De plus, la reception fait courir le délai de toutes les garanties : le délais de la garantie débute a la réception de la chose (garantie de 5 ans, 10 ans etc).

Paragraphe 4 : Coopérer

Il a une obligation de coopération (obligation de bonne fois). Il faut que le maitre de l'ouvrage coopère suffisamment pour que l'entrepreneur puisse réaliser la prestation. Par exemple faire venir un plombier mais on le laisse pas entrer dans la maison...

Section 3 : La fin du contrat d'entreprise

Le contrat d'entreprise obéit au droit commun des contrats. Mais il y a quand meme de règles particulières :

- mort de l'entrepreneur : Le contrat s'arrête mais parfois il peut mourir au milieu de la prestation. On va faire une proportion de ce qui a été réalisé et pas encore, et le maitre de l'ouvrage devra payer ce qui a déjà été fait aux héritiers de l'entrepreneur. Les héritiers pourront aussi rembourser si le maitre d'oeuvre a payer + que ce qui a été réalisé. On peut aussi prévoir dans le contrat ce qui va se passer si l'entrepreneur meurt.

- Résiliation unilatérale : **Article 1774**, lorsqu'il y a un marché a forfait, le maitre de l'ouvrage pourra résilier le contrat de façon unilatérale. Et ce, même si l'ouvrage a déjà commencé, mais il devra alors dédommager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a effectué et lui payer le manque a gagner (ce qu'il aurait pu gagner si le contrat été allé à son terme). Lorsque le maitre de l'ouvrage exerce ce droit là, il va récupérer une prestation pas terminée (ou pas commencée). Sur cette partie exécutée, il conserve le droit de se plaindre des défauts, de la mauvaise qualité de la prestation.

Chapitre 2 : Le contrat de mandat

Définit par l'article 1984 du CC, implique 3 personnes :

- mandant
- mandataire
- tiers avec le quel le mandataire va conclure un contrat au nom et pour le compte du mandant.

Le contrat qui est conclu avec le mandataire va relier le tiers au mandataire.

Le contrat de mandat implique aussi deux contrats :

- mandat lui même
- le contrat a conclure entre le mandant et le tiers

Le mandat permet la conclusion d'autres actes juridiques, va donner au mandataire un pouvoir de représentation. Il va confier une procuration, un pouvoir.

C'est donc le mandataire qui sera sur la scène juridique. Le mandant n'est pas présent. Toutefois, lorsqu'il faudra exécuter le contrat, c'est le mandant qui sera tenu.

Le contrat de mandat, a l'origine c'est un petit contrat, un contrat d'ami = il est marqué par l'**intuiti personae**. Par nature il est aussi gratuit.

Mais depuis 1804 le mandat est devenu un contrat d'affaire, et donc un contrat onéreux. Le caractère onéreux est présumé dès lors qu'il est passé entre des professionnels.

=> Contrat par lequel le mandant va donner des pouvoirs au mandataire pour faire quelque chose en son nom et pour son compte.

CM11 : 25/03

Contrat de mandat $\neq$ contrat de vente. Il y a des situations où la différence est pas si claire. Par exemple un fabricant de vêtement qui vend à des consommateurs mais il n'y a pas de relation directe entre le consommateur et le producteur.

Par exemple il peut y avoir une franchise = contrat de vente. Il peut aussi y avoir un agent commercial qui va essayer de vendre les produits etc. L'agent commercial lui est un mandataire car il n'achète pas la marchandise.

Si l'intermédiaire (on sait pas sa qualité) paye un prix fixé à l'avance, on considère que la relation est une vente. En revanche si l'intermédiaire paye pas de prix au fournisseur mais lui rend des comptes.

En matière immobilière il y a des intermédiaires immobiliers qui agissent comme des mandataires, ils facilitent la vente / achat.

Il faut agir au nom du mandant : le mandataire représente le mandant. C'est une représentation juridique. La grande question théorique est de savoir si dans le mandat il y a nécessairement une représentation ? Certains disent que oui et d'autres non. Le prof dit que oui car ça permet de distinguer le mandat d'autres opérations :

-> contrat de commission : représentation imparfaite, le commissionnaire va recevoir une mission du commettant pour qu'il accomplisse des actes juridiques pour son compte, mais en son propre nom. L'intermédiaire fait écran car agit en son propre nom.

-> Contrat de prête-nom :

-> Déclaration de command (*oui sans le E*) : opération pas très répandue mais très utilisée en matière de vente aux enchères. La personne qui vend ne veut pas être connue elle va donc chercher un commandé qui va agir pour son compte mais sans dévoiler qu'elle agit pour le compte de quelqu'un d'autre. Mais les tiers savent très bien que le commandé est un intermédiaire mais savent pas pour qui il agit.

Dans ces 3 catégories il y a une personne qui agit pour le compte du mandant. Il y a que le mandant qui en principe, tire des bénéfices de l'opération.

La JP a créé un mandat d'intérêt commun, il est onéreux : les 2 parties ont un intérêt à la réussite de l'opération. C'est le cas dans les systèmes d'agents commerciaux. Cela a entraîné une modification du contrat de mandat.

La source principale est l'**art 1984 à 2010 du CC**. En réalité, si on regarde la définition du mandat le mandataire ne correspond pas. L'agent immobilier est pas un mandataire alors que la loi prévoit que oui.

Les intermédiaires sont rarement considérés comme étant des gens honnêtes. Du coup il essaie de protéger ceux qui donnent mandat.

Section 1 : Formation du contrat de mandat

Question de la capacité des parties : contrat passé entre un mandant et un mandataire qui implique la passation d'un autre acte juridique.

- Il faut s'intéresser à la **capacité du mandant** : la capacité du mandant s'analyse à l'aune du contrat passé en son nom et pour son compte par le mandataire (s'il est pas capable de conclure le contrat pour lequel il fait mandat, le mandat sera pas valable). Quand analyser la capacité du mandant ? Au moment de la conclusion du contrat de mandat.

- il faut vérifier aussi la capacité du mandant à passer le contrat de mandat lui-même

=> Si le mandant est pas capable, le contrat de mandat est annulé et parfois le contrat passé par le mandataire aussi.

- **Capacité du mandataire** : il ne sera pas engagé par l'acte qu'il va passer, donc techniquement ce n'est pas la peine qu'il soit capable de passer le contrat. Le code civil consacre ce principe à l'article 1990 du CC : un mineur non émancipé peut très bien être mandataire pour passer des contrats (même de vente). Toutefois, le Code précise que la responsabilité du mandataire sera calculée à l'aune de sa minorité (il sera pas entièrement responsable).

Section 2 : L'objet du mandat

L'objet du mandat est l'acte juridique que le mandataire est censé accomplir au nom du mandant. L'objet doit être déterminé ou déterminable. Il faudra aussi qu'il soit licite (conforme à l'ordre public etc). Aussi, le mandant peut pas donner au mandataire + de pouvoir qu'il en a lui-même, sinon l'objet du contrat de mandat est illicite.

Le mandat peut aussi être spécial ou général (mandat pour passer un seul acte précis ou une série d'acte).

-> Le prix

Le prix n'a pas besoin d'être déterminé, ni même déterminable. Ce n'est pas une condition de validité du contrat. Elles ont toutefois intérêt à prévoir le prix et la rémunération (on parle de commission). Mais même lorsque les parties ont déterminé à l'avance le prix le juge a quand même un pouvoir de révision. Les parties ne peuvent même pas prévoir une clause qui prévoirait l'impossibilité du juge d'intervenir.

Attention : Lorsque le prix est convenu par les parties une fois la mission réalisée le juge peut plus intervenir

Section 3 : exigence de formes

Le contrat de mandat est consensuel, est pas soumis a des conditions ad valutatem de forme. Toutefois le contrat de mandat est un contrat dangereux, le mandant peut être engagé a son insu (cas de mandat tacite, comme dans le mariage etc). C'est pourquoi il existe des hypophèses de mandat solennel ou le mandat exige une forme ad valitatem. Lorsque la mission est un contrat de disposition il y a des formes a respecter.

Question sur l'acte a passer : parfois l'acte est lui même un contrat solennel. La JP distingue selon l'objectif de la formalité. Si l'objectif de la formalité est de protéger le consentement, alors le contrat de mandat devra respecter les formalités de l'acte a accomplir. En revanche si la formalité a seulement fonction d'assurer l'opposabilité aux tiers, le contrat respecte le principe du consensualisme.

Section 4 : Les effets du contrat de mandat

A - Obligations du mandataire

Le mandataire a des obligations a l'égard du mandant. Le mandataire va aussi avoir des relations avec les tiers, il faut donc s'intéresser aux deux types de relations

-> A l'égard des tiers

A priori il ne devrait pas en avoir car il a signé au nom et pour le compte du mandant. Mais il peut y avoir des acceptions :

- clause de ducroire : le mandataire garantie au tiers l'exécution de ses engagements par le mandant. = il donne une sorte de contionnement, il s'engage lui même. Cette clause n'est pas obligatoire.
- dépassement de pouvoir : lorsque le mandataire dépasse ses pouvoirs il engage sa responsabilité.
- détournement de pouvoir :

-> A l'égard du mandat

Il doit exécuter la mission qu'il lui a été confié. **L'article 1989** impose une interprétation stricte des instructions du mandant = quand y a un doute ce sera toujours pour diminuer la marge de manoeuvre du mandataire.

Obligation de résultat ou obligation de moyens ? La cour de cassation considère que l'obligation qui pèse sur le mandataire est plutôt une obligation de résultats.

Il a aussi une obligation de loyauté, il doit exécuter la mission avec une certaine loyauté. Il est censé exécuter sa mission dans le seul intérêt du mandant. Le mandataire peut il acheter le bien qu'il a pour mandat de vendre ? Être lui même le tiers ? En principe non.

Mais cette règle est que supplétive : article 1596 du CC. Le mandant a la possibilité d'autoriser le mandataire a se porter contrepartiste (il faut qu'il le sache et l'autorise).

Il doit aussi exécuter lui même la mission il peut pas y avoir de sous-mandat, sauf autorisation du mandant.

Le mandataire doit aussi rendre compte au mandant durant l'exécution de sa mission + a l'issue de la mission. Le fait de ne pas rendre des comptes est une faute grave

B - Obligations du mandant

-> A l'égard du mandataire

S'il y a une rémunération prévue il va devoir la payer. Il devra aussi éventuellement rembourser les frais et avances fait par le mandataire, voire même les pertes que ce dernier a subies à raison de sa mission.

-> A l'égard des tiers

L'article 1998 dit que le mandant est tenu d'exécuter les engagements —

Distinction :

- **régime de responsabilité pour les actes faits dans le cadre des pouvoirs donnés** : le mandant a aucune raison de se dédouaner il est engagé à l'égard des tiers. Le seul moyen pour lui de s'en sortir est de prouver qu'il y a eu un concert frauduleux entre le tiers et le mandataire.
- **régime de resp dans le cas des actes faits en dépassement de pouvoir** : le CC prévoit un principe et des exceptions.
 - ° Principe : **1998 al 2** : quand outrepassement des pouvoirs le mandant est pas engagé = l'acte est inopposable au mandant
 - ° Exceptions prévues par la loi : ratification. Le mandant accepte le dépassement de pouvoirs fait par le mandataire. Cette ratification a un effet rétroactif.
 - ° Exception : le tiers a ignoré de bonne foi que le mandat avait cessé. Le mandataire a agi alors que le mandat a pris fin et le tiers croit de bonne foi qu'il a toujours les pouvoirs. On considère que le mandant est tenu
 - ° Exception JP : la théorie du mandat apparent. Le tiers a légitimement cru au pouvoir du prétendu mandataire (il a cru que le monsieur était mandataire alors que c'était pas le cas). Le tiers va devoir démontrer l'erreur commune.

Section 5 : Extinction du mandat

Ce contrat a un régime d'extinction spécifique prévu à l'article 2003 du CC qui fait une liste.

Le contrat prend fin à la mort du mandataire car contrat intuiti personae.

On peut révoquer le contrat de façon unilatérale.

La révocation est un principe d'ordre public : dans certains cas la révocabilité est encadrée.

CM12 : 8/04

article 2004 CC

On peut révoquer un contrat de mandat « ad nutum », sur un simple signe de la tête car c'est un contrat fondé sur la confiance. Le juge n'est pas capable de savoir si oui ou non la confiance a légitimement disparu. Ainsi, on dit que le principe, d'ordre public, est la révocabilité ad nutum = on décide souverainement, unilatéralement, de mettre fin au contrat.

Cela veut dire que l'exercice de cette révocation ne peut pas être jugée comme préjudiciable etc, il n'y a pas d'indemnité à payer.

Mais cela ne veut pas dire que ce principe ad nutum autorise tous les comportements, c'est une liberté protégée certes mais on ne doit pas en abuser (accompagner cette révocation d'insultes, de propos vexatoires), ce qui va motiver d'éventuels dommages et intérêts pour réparer l'abus à côté de la révocation.

-> Mais alors peut-on intégrer dans le contrat une clause d'irrévocabilité ?

Cela arrive fréquemment dans les contrats commerciaux. Personne n'a dit que ces clauses sont nulles, elles sont valables. Mais alors sont-elles parfaitement efficaces, est-ce qu'elles se réalisent comme elles sont prévues ?

Non.

Elles empêchent pas la révocation du mandat, aucun juge ne viendra prononcer la poursuite forcée du mandat. En revanche, il y a une conséquence à la révocation d'un contrat avec une clause d'irrévocabilité : indemnisation. Le mandataire va toucher l'indemnité sans avoir à prouver un abus accessoire à la révocation. À partir du moment où il y a une clause d'irrévocabilité et que le mandant révoque = indemnisation.

Dans un contrat qui ne comporte pas de clause d'irrévocabilité, c'est au mandataire de rapporter la preuve qu'il a subi un abus à côté de la révocation du mandat.

B - Le mandat d'intérêt commun

C'est un mandat donné dans l'intérêt à la fois du mandant et du mandataire. Les 2 tirent un intérêt de l'exécution de ce contrat. Ce contrat s'est petit à petit commercialisé, et dans toutes ces hypothèses là les 2 parties avaient un intérêt. La cour de cassation a donc en 1873 dit que le contrat n'est plus révocable unilatéralement mais par consentement mutuel. => Les parties doivent être toutes les deux d'accord.

Mais ce principe n'est pas réellement remis en cause car le juge ne prononcera pas la poursuite forcée du contrat. Ainsi, la révocation ne sera pas interdite, mais le mandataire pourra obtenir une indemnisation.

Mais alors comment on reconnaît un mandat d'intérêt commun ? Le caractère onéreux ne suffit pas, il faut un +. C'est la JP qui a développé ce +. Il faut que les 2 parties participent à la création ou au développement d'une clientèle commerciale commune.

Cette notion de mandat d'intérêt commun est seulement jurisprudentielle, elle n'est pas encore prévue dans le CC (mais dans le projet de réforme ..)

Titre IV - Le contrat de dépôt

C'est un contrat qui porte sur une chose, c'est un contrat réel. Sauf qu'à la différence d'autres contrats, il n'est pas là pour assurer un transfert de propriété, ni de permettre l'usage de la chose. Ici, le dépôt sert à garder une chose.

Ce contrat permet au déposant de demander au dépositaire de conserver la chose.

Le CC à l'article 1915 dit que c'est « l'acte par lequel on reçoit ... »

Ce contrat est utilisé de façon différente : au départ c'est un contrat gratuit, d'ami, mais il s'est commercialisé. C'est un contrat qui est proposé en masse au consommateur : vestiaires dans une boîte de nuit par ex.

Dans ce contrat il y a une obligation de restitution (donc pas de transfert de propriété).

Aussi, cette obligation de restitution est tellement forte qu'elle empêche d'utiliser le bien = permet de distinguer le contrat de dépôt du contrat de prêt.

Puis il y a également une obligation de garde, c'est l'essence même de ce contrat, c'est l'obligation la + importante.

Cela permet de distinguer aussi du contrat de dépôt du contrat de bail, ou même du contrat de mandat.

Chapitre 1 : Droit commun du dépôt

Section 1 : Formation du contrat de dépôt

A - Objet

Le contrat de dépôt ne peut pas porter sur tout type de chose : il ne peut porter que sur des choses, pas des personnes (on ne dépose pas un enfant à la crèche).

Il y a uniquement les biens meubles, pas immeuble (car pas de remise de la chose).

B - Le prix

Le contrat de dépôt est un contrat d'ami, donc gratuit. Mais rien interdit de stipuler un prix, le contrat va donc devenir onéreux. Ainsi, le prix n'a pas à être déterminé ou déterminable.

Le prix n'a pas à être formellement onéreux tout en étant payant —

C - La forme

Le contrat obéit à une exigence de forme car contrat réel. C'est ce que dit l'article 1919 : le contrat est -

Ça ne sert à rien de faire des promesses de dépôts car elle ne se résoudront jamais par une exécution forcée.

Section 2 : Les effets du contrat de dépôt

A - Les obligations du dépositaire

Pèse sur le dépositaire une obligation de garde. En réalité elle se décline, elle oblige à aller plus loin. Cela veut dire que : il ne faut pas faire un certain nb de chose + obligation de faire.

- obligation de ne pas faire : le dépositaire ne peut pas faire **d'abus de confiance** (délit civil mais aussi délit pénal). Si

on viole les obligations du contrat on abuse de la confiance

mais les parties peuvent mettre de côté cette obligation : le déposant peut autoriser le dépositaire d'utiliser la chose

-> Obligation de ne **pas consommer le éventuels fruits** de la chose. Il va avoir gardé les fruits mais il ne pourra pas les consommer. Là encore, le déposant peut autoriser le dépositaire à consommer les fruits. Attention toutefois, s'il l'autorise ce ne sera plus un contrat gratuit.

-> Interdiction au dépositaire de **connaître la chose** si le déposant lui a remis une chose cachée (une enveloppe fermée par ex). Là encore, le déposant peut l'autoriser à le faire, mais il faut une autorisation.

- Obligations de faire : **obligation de conservation**, c'est-à-dire une obligation de moyens renforcée.

Le dépositaire répond des détériorations de la chose, s'il y a des défauts sur la chose il en est présumé responsable (il devra prouver son absence de faute).

Cette obligation implique aussi d'assurer la chose : il faut être assuré pour garder la chose. Ce qui va permettre au déposant soit de récupérer sa chose, soit de récupérer l'indemnité de l'assurance s'il y a eu un sinistre.

Mais comment apprécier la resp du dépositaire ? En fonction du caractère gratuit ou onéreux.

Si gratuit : on va apprécier le comportement du dépositaire en fonction du standard du « bon père de famille ». On va vérifier si le dépositaire va accorder à la chose les mêmes soins qu'il aurait apporté à sa propre chose.

Si onéreux : on sera + sévère avec le dépositaire et on attendra de lui qu'il apporte les soins maximum à la conservation de la chose en rapport avec le prix qu'il demande.

Il va aussi **devoir restituer** la chose à la fin du contrat. Il doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue.

Comme dans le contrat de prêt il va falloir analyser si la chose déposée est consomptible ou pas. Quand c'est une chose consomptible qui est déposée il faudra restituer une chose de même valeur. Si pas consomptible il faudra restituer la même chose qui a été déposée.

-> Il devra aussi rendre les fruits (sauf autorisation de la part du déposant).

=> Question de savoir à qui il doit restituer la chose : il doit restituer non pas au propriétaire de la chose mais au déposant.

Quand faut-il restituer ? Il faut restituer au moment où le déposant demande la restitution et ce, peu importe la durée du contrat de dépôt. => Principe de révocation ad nutum.

B - Obligation du déposant

Il aura l'obligation de payer si le contrat est payant. Il devra rembourser les éventuelles pertes subies par le dépositaire à raison de la conservation du bien déposé.

Le dépositaire bénéficie d'un droit de rétention, tant que le déposant n'a pas payé le dépositaire pourra conserver la chose, mais que pour des créances liées au contrat de dépôt.

Chapitre 2 : Le dépôt particulier

Certains sont prévus dans le code civil : le contrat de dépôt a été vu par le législateur comme susceptible de déclinaisons particulières.

Section 1 : Le dépôt nécessaire

Le premier dépôt est le **dépôt nécessaire**, envisagé par l'article 1949 du Code civil. C'est un dépôt qui par définition est pas totalement volontaire, il est pas voulu par le déposant, il a été forcé par quelque accident : incendie, pillage, ruine etc.

Première question : est-ce un contrat ? Oui, même s'il y a pas de rencontre de volonté. Le consentement du déposant s'exprime même s'il est forcé, mais le dépositaire lui est consentent.

C'est un contrat qui va se prouver par un témoignage (sauf au delà de 1500€ ou il faudra un contrat écrit).

Section 2 : Le dépôt hôtelier

Le CC fait de ce dépôt un dépôt nécessaire. Rien oblige au client de déposer ses affaires dans l'hôtel, c'est pas nécessaire. Mais pour protéger les clients d'hôtel on estime que c'est un contrat nécessaire, voir même inconscient. (on a pas l'impression de faire un contrat de dépôt quand on dépose ses affaires à l'hôtel).

Pour ce dépôt nécessaire le CC a prévu un régime particulier : article 1952 et suiv.

c'est un régime de resp de l'hôtelier. L'hôtelier est considéré comme le dépositaire : il est responsable d'une obligation légale et spécifique de conservation, prévue aux articles 1952 et 1954 du CC. Il est resp des vols et dommages causés aux effets des clients. Le seul moyen pour lui de s'exonérer est de prouver un élément de force majeure, la perte résulte de la perte ou du vice interne de la chose, ou alors la perte de la chose est la faute du client.

De plus, il est responsable pour autrui : si le vol est commis par un de ses employés ou par un voleur externe, l'hôtelier est resp de tout. (il est censé surveiller son hôtel).

Toutefois le CC prévoit une limitation de la resp de l'hôtelier : il est resp dans certaines limites de valeurs.

- Quand les biens sont laissés dans un véhicule dont l'hôtelier a la jouissance ou sur le parking de l'hôtel, la réparation sera limitée à 50x le prix de la chambre.

- si le vol / dommage a atteint des choses introduites dans l'hôtel (dans la chambre par ex), cette fois la limitation est portée à 100x le prix de la chambre.

- La seule hypothèse pour laquelle l'hôtelier a eu une resp illimitée est lorsque les biens volés ou abîmés lui ont été remis en main propre = il est totalement responsable.

Section 3 : Le dépôt hospitalier

Ce dépôt est pas prévu dans le CC mais dans le code de la santé publique mais clairement organisé sur le modèle du dépôt hôtelier. Il est là pour organiser la resp des établissements qui reçoivent des malades etc, et qui en accessoire de leur service médical offrent des services hôteliers / para-hôteliers.

Raison pour laquelle le législateur a prévu pour ces établissements un dépôt spécifique qui ressemble fortement au dépôt hôtelier.

Il y a une resp aggravée car resp de plein droit qui pèse sur l'établissement.

-

Toutefois la limite du plafond et deux fois le plafond de la sécurité sociale. Toutes les choses ne sont pas découvertes par le régime du dépôt hospitalier, ce régime ne s'applique qu'aux choses dont la nature justifie leur détention par le patient hébergé.

Section 4 : Le séquestre

Le contrat de séquestre est défini dans **1956 du CC** : c'est le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui la rendra une fois la contestation terminée à la personne qui aura le droit de l'obtenir.

Quand le litige sera tranché on pourra désigner la personne à qui il faudra restituer la chose.

La chose déposée fait donc l'objet d'un litige, on ne sait pas très bien à qui elle appartient et permet de passer le temps en attendant la résolution de la chose.

- séquestre conventionnel : elles sont pas d'accord entre elles mais d'accord pour protéger la chose en la plaçant chez un tiers
- séquestre judiciaire : le juge décide lui-même de placer la chose

La personne qui reçoit la chose, le séquestre, aura les mêmes obligations qu'un dépositaire ordinaire. Le séquestre devra conserver la chose et la restituer, et la plus part du temps ce sont des séquestres onéreux.

Aussi, le séquestre prend fin lorsque le litige prend fin. Mais il se peut qu'on ait passé un séquestre pour une durée de 3 mois mais qu'au bout des 3 mois le litige soit pas tranché, du coup ça on sait pas.